



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

תיק מס': 281/12+210/12

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

התובעת: **די ג'יי אסוסיאטס אינק ח.פ. 56002313-7**
והנתבעת: **ע"י ב"כ עו"ד מתן וינברג**
שכנגד

- נ ג ד -

הנתבעת: **נציגות הבית המשותף בבית עומר**
והתובעת: **ע"י ב"כ עו"ד שי אניספלד ועו"ד יניב טיש**
שכנגד

פ ס ק – ד י נ

תביעה ותביעה שכנגד שעניינן העיקרי בשאלה האם מוסמכות הנציגות או האסיפה הכללית של בעלי הדירות להורות על שינוי אופן הנשיאה בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, כך שחניות ומשטחים המוצמדים ליחידות המשנה, ומושכרים לשם שימוש מסחרי, יחויבו בנפרד בהוצאות אלו. ברקע הדברים, התקנון המוסכם הקובע כי שטחי ההצמדה לא יילקחו בחשבון במסגרת חישוב שטח רצפת הדירות לצורך גביית הוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, אך עם זאת כי על בעלי יחידות המשנה להשתמש ביחידותיהם "שימוש יעיל וסביר".

כן עוסק הליך זה, בין היתר, בשאלה האם הסכמת בעל יחידה לשינוי שיטת החישוב מחייבת את חליפו, ובאילו נסיבות.

א. העובדות

1. עסקינן בבית משותף, המשמש עסקים מסחריים, הידוע כגוש 30262 חלקה 138. בית זה מוכר כ"בית עומר", והוא ממוקם ברחוב בית הדפוס 22 באזור התעשייה גבעת שאול בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**").
2. הבית המשותף מונה 31 חלקות משנה. התובעת והנתבעת שכנגד, בעליה של יחידת משנה 8, וחוכרת לדורות של ההצמדות קצ' - קצד' של יחידת משנה 31 (להלן: "**התובעת**" או "**די ג'יי**"). הנתבעת והתובעת שכנגד היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**").
3. שטחה של יחידת משנה 8 היא 546.6 מ"ר ומוצמדות לה 20 חניות מקורות (הצמדות סח' - ק'), בקומה 2 - של חניון הבית המשותף (קומת מרתף שניה לפי תשריט הבית המשותף - להלן: "**חניון 2**"). יחידת משנה 8, הממוקמת בקומת הכניסה לבניין, מושכרת לחברת ביקור רופא, משרדי חברת אלדן, ושתי חנויות נוספות.
4. הצמדות קצ' - קצג' הם ארבעה מחסנים. הצמדה קצד' היא משטח המתפרש על פני שטח של 2,605 מ"ר (להלן: "**המשטח**"). המשטח מהווה את מלוא קומה 1 - של חניון הבית המשותף, היא קומת מרתף שלישית לפי תשריט הבית המשותף (להלן: "**חניון 1**").



משרד המשפטים לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין ירושלים

5. המשטח מושכר ברובו לחברת אלדן תחבורה בע"מ (להלן: "אלדן"), וכמו כן מושכרות לה 20 החניות הצמודות ליחידת משנה 8, והממוקמות בחניון 2. בשטחים אלו עושה אלדן שימוש לצורך החניית רכביה (בין הצדדים ניטשה מחלוקת באשר לפעולות נוספות שעושה אלדן במשטח ובחניות המושכרות לה, אולם לכך אשוב בהמשך).
6. מהסכם השכירות המקורי בין קודמיה של די גיי לבין אלדן מיום 26.8.07 (להלן: "ההסכם המקורי"). ראה הסכמי השכירות אשר צורפו ל"הודעה מטעם התובעת" מיום 4.6.13, נספח ט לתצהיר אמיר שושני) עולה כי לאלדן הושכרו 100 חניות. בנספחים המצורפים להסכם השכירות, כפי שהובאו לעיוני, מסומנות 89 חניות בלבד- 69 בקומת חניון 1, ו-20 בקומת חניון 2 (קומת המרתף השנייה). מכל מקום, בתוספת להסכם השכירות הבלתי מוגנת מיום 17.7.12, שהפעם נחתמה בין די גיי לאלדן (להלן: "התוספת להסכם"), עולה כי 11 חניות נוספות שהושכרו לאלדן בהסכם המקורי, ולפי התשריט המצורף לנספח ג' ממוקמות בחניון 2, אינן נכללות עוד במושכר.
7. בנוסף, התובעת השכירה שטח של 20 חניות בקומת חניון 1- (במשטח) לחברת מצרי התקנות ושיווק בע"מ (להלן: "מצרי"), ראה התשריט המצורף להסכם השכירות עם מצרי מיום 11.6.12 – להלן: "חוזה מצרי") למטרת התקנות של אביזרי רכב (יוער כי לפני מצרי שכרה חניות אלו חברת "פון לי", אשר עשתה בהן שימוש דומה- ראה בהקשר זה גם האמור בהגדרת "המושכר" בהסכם השכירות עם אלדן מיום 26.8.07). מכל מקום, ככל הנראה במהלך ניהול הליך זה, חדלה מצרי מלשכור ולהשתמש בשטחים אלו, והתפנתה מהם.
8. יוצא כי סך הכל, עושה התובעת באמצעות מי מטעמה שימוש ב-109 חניות, הן בקומה 1- והן בקומה 2-.
9. חלק מהמשטח והחניות בקומה 2- כפוף לזיקת הנאה שמהותה העיקרית זכות למעבר חופשי ברכב וברגל ליתר בעלי הדירות, זאת בהתאם לסימונים המופיעים בתשריט בשטח המקווקו באדום (ראה הערות בדבר זיקות להן כפופה חלקה 31, כעולה מנסח המקרקעין).
10. לבית המשותף תקנון מוסכם וכן תקנון מוסכם מתוקן אשר הוסיף על כמה מהוראותיו (להלן יכונן יחד, לשם הנוחות, "התקנון המוסכם"). התקנון המוסכם עוסק, בין היתר, בשיטת חישוב דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף ובחובות השונים החלים על בעלי יחידות המשנה בבית המשותף. יש לציין כי הבית המשותף נרשם ככזה בשנת 2006, ומטבע הדברים, במועד זה גם ניתן תוקף לתקנון המוסכם, אולם הוא אוכלס ושימש בפועל עסקים מסחריים שנים קודם לכן (ככל הנראה משנת 1998 ואילך, או בקרוב לכך).
11. הנציגות הודיעה לשוכרי התובעת, במכתבים מיום 2.5.12, כי יחול שינוי בדמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף (להלן: "מכתב השינוי"- ראה נספח 33 לכתב התביעה). במכתב שהופנה באותו יום לאלדן צוין, בין היתר, כך:

" עקב הסדרת רישום היחידות בטאבו החליטה נציגות הדיירים להתאים את שינוי אופן חישוב דמי הניהול לרישום.

החל מתאריך 1.4.12 חיוב השטח ייקבע לפי גודל היחידה הרישום בטאבו, ללא הצמדה של השטחים המשותפים בסך 32% כפי שחושב עד כה. במקביל, דמי הניהול למטר יעלו, כך שהתשלום החודשי אמור להישאר ללא שינוי.

חניות יחויבו לפי שטח בטאבו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

יחידות או דיירים להם קיימים שטחים בעלי שימוש אחר כגון מחסנים, מחסנים בחניות אזור תפעול ותחזוקה - ישלמו דמי ניהול על שימושים אלו בהתאם למקובל בבניינים אחרים ובתקנון הבית המשותף...

12. ממכתב זה עולה עוד כי הנציגות דרשה שעבור "חניה עם שימוש תפעולי" תשלם התובעת דמי ניהול בגובה השווה לאלו שחלים על כל דירה אחרת (היינו 12.7 ₪ למ"ר). עבור שטח מחסנים מחצית מכך (6.35 ₪ למ"ר), ועבור שטח חניה "רגיל" - 4 ₪ למ"ר (להלן: **"שיטת החישוב החדשה"**). יש לציין כי טרם שיטת החישוב כאמור לעיל, נגבו דמי הניהול לפי גודל יחידת הדיור בתוספת 32% עבור הצמדת השטחים המשותפים. ביחס לחניות נגבה בשלב הראשון סכום של 45 ₪ עבור כל חניה, ומאוחר יותר 44 ₪ לחניה (להלן: **"שיטת החישוב הישנה"**).

13. לפי מכתב השינוי, חויבה אלדן עבור יחידה בשטח של 130.02 מ"ר לפי 12.7 ₪ למ"ר, שטח חניה של 2,086.8 מ"ר לפי חישוב של 4 ₪ למ"ר, וחניה עם שימוש תפעולי בשטח של 542 מ"ר לפי חיוב של 12.7 ₪ למ"ר. שוכרת נוספת של התובעת, מצרי, חויבה עבור 20 חניות עם שימוש תפעולי, בשטח של 333.146 מ"ר, לפי חיוב של 12.7 ₪ למ"ר.

14. **משמעות שינוי שיטת החישוב כאמור לעיל, היא העלאת גובה דמי הניהול החלים על התובעת, במאות אחוזים.**

15. התקנון המוסכם קובע, בכל הנוגע לגביית הוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, כי שטחי ההצמדות (למעט חריגים) לא יכללו בחישוב שטחי יחידת המשנה, לצורך חישוב חלקם בהוצאות הרכוש המשותף. לשון סעיף 3.3 לתקנון המוסכם שכותרתו **"נשיאה בהוצאות"** הוא כדלהלן (יוער כי לעניין זה משולבת בציטוט הבא התוספת לנוסח הסעיף כפי שבאה לידי ביטוי בתקנון המוסכם המתוקן) :

"נקבע בזה בהתאם לסעיף 58 לחוק (חוק המקרקעין התשכ"ט-1969- להלן: "החוק"- י.ע.ש) להלן:

בעלי יחידות המשנה, למעט יחידת משנה מס' 138/1, בבית המשותף יישאו בכל הוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף, לפי יחס שטח רצפתה של יחידת המשנה שבבעלותם לכלל שטח הרצפות של כל היחידות בבית המשותף, ללא השטח הצמוד לה בצמידות מיוחדת, למעט שטח ממ"ק שצמוד ליחידה או מהווה חלק ממנה שיווסף לשטח היחידה, ולמעט שטח מחסנים שאינם בקומות החנייה אשר ייוספו לשטח היחידה תוך הכפלה במקדם של 50% כמפורט בטבלה שלעיל. כמו כן יחידות המשנה המהוות ומשמשות מחסנים יישאו בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף בשיעור של 50%, מיחידות משנה שאינן מהוות ומשמשות למחסנים. יחידת משנה 138/1 תשלם 1 ₪ לשנה עבור הוצאות החזקה וניהול של הרכוש המשותף". (ההדגשות שלי- י.ע.ש).

16. סעיף 9.1 לתקנון קובע כי :

"על כל בעלי יחידות המשנה להשתמש ביחידותיהם שימוש יעיל וסביר מתוך מתן הדעת על הצורך לאפשר ליתר הדיירים שימוש נאות ביחידותיהם, ברכוש המשותף ובדרכי המעבר. בפרט, חל איסור מוחלט על סתימת וחסמת דרכי המעבר ברכוש המשותף, ובמשטחים המפורטים בסעיף 6 לעיל ועל הרמת חפצים המונעים ו/או המפריעים לשימוש בהם".

17. כאמור, בהליך שבנדון הגישה די גיי תביעה כנגד הנציגות וכן הוגשה תביעה שכנגד. בתביעתה של די- גיי מבוקש סעד הצהרתי ולפיו "הנתבעת איננה רשאית להעלות את תעריפי דמי וועד הבית באופן שבו הם ייגבו בניגוד



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

להוראת התקנון, ללא עריכת שינוי בתקנון הבית המשותף, באופן הקבוע בחוק" וכן נתבע סך של 147,430 ₪, בגין "השבת הסכומים אשר נגבו על ידי הנתבעת ביתר מיום רכישת הנכס על ידי התובעת ועד ליום הגשת כתב תביעה זה".

18. **בתביעה שכנגד**, עותרת הנציגות, בין היתר, לסעד כספי בסך של 349,933 ₪. הנציגות טוענת כי לדי ג'יי יתרת חוב עבור השנים 2008-2011 בסך 79,631 ₪, וזאת בגין החניות, המחסנים והמשטחים שהיא בעלת הזכויות בהם. בנוסף, חוב בסך 16,027 ₪ בגין חנות, אשר שימשה את בית הקפה "בבוש" ולטענת הנציגות לא שולם עבורה דמי ניהול. עוד נטען כי קיימת לדי ג'יי יתרת חוב, עבור שנת 2012, העומדת על סך כולל של 193,474 ₪. בנוסף, נטען כי די ג'יי השתמשה לצרכיה הפרטיים, באמצעות שוכריה, בתשתיות מים וחשמל השייכות לרכוש המשותף, כאשר סך החוב הנתבע בגין רכיב המים הועמד על 10,800 ₪, נכון ליום הגשת התביעה. בנוסף, עותרת הנציגות לדמי שימוש בגין חניות ברכוש משותף או ב"שטחי מעבר", בסך של 50,000 ₪ (לצרכי אגרה לפי הנתען בכתב התביעה שכנגד).

19. כמו כן עותרת הנציגות לשני סעדים הצהרתיים: האחד, כי השימוש שעושה הנתבעת בחניון, על ידי הפיכתו לחניון תפעולי, הוא בלתי סביר וכמוהו כהסגת גבול, והשני, כי הנציגות הייתה רשאית לגבות דמי ניהול או אחזקה מדי ג'יי עבור השימוש בחניון ורשאית הייתה להחליט לגבות דמי ניהול בגין שימוש תפעולי של החניון, השימוש בחניות, במשטחים שהוסבו לחניות ובמחסנים שהוסבו למשרדים תפעוליים. כן התבקשו צווי עשה-להורות לדי ג'יי להשתמש במחסנים ככאלו ולא כמשרדים, להורות לדי ג'יי שלא להשתמש במשטחים כחניות, וכן להורות לה שלא לחנות בשטחי המעבר ולא לחסום אותם.

20. בהליך שבנדון התקיימו מספר דיוני הוכחות. כמו כן ערכתי ביקור במקום בנוכחות נציגי הצדדים ובאי כוחם ביום 28.1.14. קיימתי ביקור נוסף במקום שלא בנוכחות הצדדים, ומבלי שעודכנו בביקור זה, ביום 28.8.14. לאחר הגשת הסיכומים זימנתי את הצדדים לדיון נוסף בפניי (אשר התקיים ביום 27.7.14) וזאת בניסיון נוסף להגיע לפשרה המוסכמת על כל הצדדים. משהודיעה די-ג'יי כי אינה מקבלת את הצעתי, לא נותר לי אלא להכריע במחלוקות על פי שורת הדין.

21. בהתאם להחלטתי מיום 3.9.14 הגישו הצדדים השלמת טיעון בשאלה האם המשתתפים באסיפה הכללית מיום 20.2.08 היוו את רוב בעלי הדירות אשר שני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

ב. תמצית טענות הצדדים

הצדדים העלו בסיכומיהם טענות רבות ושונוות, מן הגורן ומן היקב. בפרק זה יפורטו בקצרה העיקריות שבהן, אלו הנדרשות להכרעה במחלוקות לשם בחינת הזכאות לסעדים המבוקשים בכתבי התביעה, בבחינת ברירת המוץ מן התבן.

עיקרי טענות די ג'יי

22. די ג'יי טוענת כי השינוי בגביית דמי הניהול בבית המשותף מנוגד באופן ברור להוראות התקנון, ולפיכך אין הנציגות רשאית לבצע את השינוי כפי שביצעה, שכן הוראות התקנון המוסכם לא שונו בהתאם.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

23. לטענת די גיי, בבדיקה שערכה הסתבר כי היא אף חויבה ביתר בגין יחידותיה במהלך השנים, ולפיכך היא זכאית לסך של 147,430 ₪.
24. בכל הנוגע לתביעה שכנגד, טוענת די גיי את הטענות הבאות:
25. לטענת די גיי, לשיטת החישוב החדשה, אשר לטעמה סותרת את הוראות התקנון המוסכם, לא קדמה קבלת החלטה באסיפה הכללית ולא נתקבלה הסכמת די גיי כנדרש לפי סעיף 62(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969.
26. די גיי טוענת כי יש לדחות את טענת הנציגות להסכמת קודמה, המחייבת כביכול גם אותה, שכן כלל לא הוכח כי קודמה אכן נתן הסכמתו לשיטת החישוב החדשה כנטען, שכן הנציגות נמנעה מלהעיד את מי שהיו נוכחים באותה אסיפה בה נטען כי ניתן אישור זה. מכל מקום, נטען כי בהחלטת האסיפה הכללית הנוגעת לשינוי שיטת החישוב, נפלו פגמים המעלים ספק ממשי בתוקפה. לכל היותר, כך טוענת די גיי, החלטה זו יכולה לחייב את המסכים לה, אך לא את הבאים בנעליו.
27. לטענת די גיי, גם אם מי שקדם לה כבעל הזכויות, הסכים בשלב כלשהו לשלם מעבר לרשום בתקנון המוסכם, הרי שהסכמה זו אינה מחייבת אותה, כיוון שהיא לא קיבלה תוקף במרשמים הפומביים. נטען כי לפיכך ההחלטה המשתקפת במכתב השינוי משוללת כל תוקף ומנוגדת לתקנון המוסכם, ויש להורות על בטלותה.
28. טענה נוספת שמעלה די גיי היא כי אף אם היה תוקף להחלטה בדבר שינוי שיטת החישוב (דבר המוכחש על ידה), הרי שעומדת לה הזכות להפסיק את התשלומים, אותם היא משלמת מעבר לחובתה בתקנון, בכל עת. לפיכך, נטען, כי החל מהמועד בו הנציגות החליטה על שיטת החישוב החדשה ודי גיי סירבה לכך ודרשה לקבל בחזרה את הסכומים ששילמה ביתר, דמי הניהול צריכים לחזור ולהיות משולמים לפי הוראות התקנון המוסכם, כך שלא ייגבו דמי ניהול עבור החלקים המוצמדים ליחידות המשנה.
29. באשר לטענות הנציגות בדבר סוג השימוש שעושה די גיי בחניות, במחסנים ובמשטחים שבבעלותה, נטען כי התקנון המוסכם אינו מגביל את סוג השימוש, וכי לו רצה מנסח התקנון למנוע שימושים כלשהם - היה עושה זאת במפורש.
30. לטענת די גיי, המפקחת על רישום מקרקעין אינה מוסמכת לדון בתביעה ככל שהיא נוגעת לטענות מתחום דיני עשיית עושר ולא במשפט, ייעוד הבניין, החניון, והשימושים שנעשים בהם בפועל. נטען כי מאחר שהתקנון אינו מגביל את סוגי השימוש המותרים בחניות, במחסנים ובמשטחים, אזי כל טענות הנציגות לשימוש וייעוד החניון ואופי הפעילות העסקית המבוצעות בו, אינן בסמכותה של ערכאה זו. די גיי טוענת כי עיקר הטענות הן מסוג של עוולת מטרד או הפרת חובה חקוקה ואלו אינן מצויות, כאמור, תחת מטריית סמכויות המפקחת.
31. באשר לדרישה לתשלום דמי שימוש ראויים עבור חניות בשטחי מעבר או ברכוש משותף, נטען כי כלל אין מדובר ברכוש משותף וכי המשטח בקומת חניון 1- שייך כולו לדי גיי, לרבות השטחים בהם קיימת זיקת הנאה לצרכי מעבר. במצב דברים זה, הרי שאין מדובר בהסגת גבול. לפיכך, נטען, אין ערכאה זו מוסמכת לדון בטענות אלו, המושתתות על עילה של עשיית עושר ולא במשפט במנותק מעילת הסגת גבול.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

32. לגופו של עניין ולמען הזהירות, טוענת די ג'יי כי אין ממש בטענות הנציגות בדבר "הסבת" המשטח לחניות, וכי מאז ומעולם שימש המשטח כחניות. כך גם נטען שאת המחסנים הממוקמים בקומת חניון 1- (הצמדות קצי-קצג') לא הסבה די ג'יי ל"משרדים תפעוליים", אלא ששימוש שכזה התקיים משך שנים רבות עוד טרם שדי ג'יי רכשה את זכויותיה בבניין.

33. לטענת די ג'יי, כאשר בוחנים "שימוש סביר" מהו, יש לעשות זאת, כפי שנקבע בפסיקה, "על פי תנאי הזמן והמקום". במקרה בו עסקינן בבית משרדים המצוי באזור תעשייה הומה, כבמקרה דנן, מדובר בשימוש סביר ובוודאי שהוא אינו מונע שימוש זהה מיתר הדיירים.

34. בהתייחס לטענות בדבר חסימת שטחי מעבר, נטען כי הנציגות כלל לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה. נטען כי חניון הבניין פתוח לכל דכפין וככל שקיימות חסימות הן נעוצות בטעם זה ואין לתלותן בהשכרת המשטח והחניות לאלדן ולשוכרים נוספים. עוד נטען, כי ממועד אכלוס הבניין לא סימן מודד מוסמך את שטחי המעבר, ובאין סימון כזה לא ניתן לקבוע מתי מדובר, אם בכלל, בחסימה. נטען כי טענות בדבר חסימת שטחי מעבר וסימון שטחי מעבר צריכות היו להיות מוכחות באמצעות חוות דעת מודד, ומשזו לא הוגשה - כי אז לא הוכחה טענת הנציגות. מכל מקום, נטען, הדרישה הכספית בגין "דמי שימוש ראויים" מתבססת על חישוב שערך גורם אשר לא העיד בהליך זה, ולפיכך חישוב זה כולו מהווה עדות מפי השמיעה שאינה קבילה.

35. די ג'יי מכחישה מכל וכל את החוב הנטען, לרבות בגין רכיבי השימוש בחשמל ובמים המשותפים, ומפרטת בסיכומיה את הטעויות שנפלו, לשיטתה, בחישוביה של הנציגות בדבר החוב הכספי הנתבע. לבירור נושא זה נשוב בפירוט בהמשך הדיון.

עיקרי טענות הנציגות

36. לטענת הנציגות, קודמיה של די ג'יי בבעלות על חלקות משנה 8 ובהצמדות הרלוונטיות לתת חלקה 31, נתנו הסכמתם להפרדה חשבונית בין דמי הניהול של היחידות לאלו של החניון. נטען כי הסכמה זו, אשר נתקבלה באסיפה הכללית של בעלי הדירות, מחייבת גם את די ג'יי כמי שבאה בנעליהם, ועל כן היא מושתקת מלטעון כנגדה.

37. בנוסף טוענת הנציגות כי ב"כ התובעת ונציגה, עו"ד אמיר שושני (להלן: "שושני"), הסכים באופן אישי להפרדת דמי הניהול. בעניין זה מפנה הנתבעת למכתבו של שושני מיום 25.12.08 (נספח ח' לכתב ההגנה) בו הוא מציין, בין היתר, כי "עניין העלויות יוסדר, כפי שהוסדר בעבר, באמצעות קביעת דמי ניהול בגין חניות, אשר יכסו את העלויות שנובעות מהצורך בשמירת אוויר נקי".

38. נטען כי די ג'יי נהנית משירותי אחזקת החניון ואין זה סביר כי בעלי יחידות שאין להם חניות או שיש להם מספר מועט של חניות, יממנו את שירותי האחזקה והבלאי של די ג'יי ושוכריה.

39. הנציגות טוענת כי ללא הפרדה חשבונית בין עלויות האחזקה של החניון לעלויות האחזקה של המשרדים, אין לה כל חבות לספק שירותי אחזקה, תחזוקה וניקיון לשטחים המצויים בבעלותה הפרטית של די ג'יי.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

40. כן טוענת הנציגות כי שוכרי התובעת הם ששילמו עבור דמי הניהול, ולא התובעת עצמה, ועל כן אין להם כל עילת תביעה כספית כנגד הנציגות.
41. לטענת הנציגות, לשוכרי די גיי חובות עבר בגין דמי ניהול אשר לא שולמו במועד.
42. הנציגות טוענת עוד, כי התעלמות מהשימוש שנעשה בחניון בפועל, כיחידה תפעולית ומניבה לכל דבר ועניין, תהייה מתן אפשרות לתובעים לעשות עושר ולא במשפט על גבם של בעלי הדירות האחרים.
43. הנציגות טוענת כי יש לייחס חשיבות רבה להוראת סעיף 9.1 לתקנון המוסכם הקובעת, בין היתר, כי **"על כל בעלי יחידות המשנה להשתמש ביחידותיהם שימוש יעיל וסביר ..."**. נטען כי יש לפרש את הוראות התקנון המוסכם בהתאם לתכליתן, כאשר אומד דעת הצדדים כפי שמשקף מהתקנון המוסכם, אינו מאפשר לתובעת להפעיל את החניון כחניון תפעולי אשר גורם למטרדים והוצאות נוספות, מבלי שהדבר ישתקף בדמי הניהול הנגבים. נטען, כי בשים לב לשימוש שנעשה בחניות ובמשטחים, שאינו שונה מכל שימוש מסחרי אחר, יש הצדקה לגבות דמי ניהול ראויים ורגילים, כפי שנגבים משאר בעלי הדירות בבית המשותף.
44. הנציגות מלינה על חסימות חוזרות ונשנות של שוכרי די גיי, ובראשם אלדן, של שטחי המעבר בחניון. הנציגות טוענת כי על די גיי לשלם לה דמי שימוש ראויים עבור פלישת די גיי או שוכריה לתחום שטחי המעבר ולרכוש המשותף, שכן היא מחנה את רכביה בשטחים אלו.
45. לטענת הנציגות, השימוש שעושה די גיי במשטח ובחניות הוא שימוש בלתי סביר שכמוהו כהסגת גבול ושימוש חורג.
46. הנציגות טוענת כי די גיי, באמצעות שוכריה, עושה שימוש בחשמל ובמים המהווים רכוש משותף, לצרכיה הפרטיים.
47. בסיכומיה טענה הנציגות לראשונה כי למעשה התקנון המוסכם נרשם במרמה ולפיכך בטל, ועל כן יש להחיל על הבית המשותף את הוראות התקנון המצוי.
48. הנציגות העלתה בסיכומיה טענות רבות ונוספות הנוגעות בעיקרן להתנהלות די גיי במהלך ניהול ההליך, לקבילות או משקל העדויות מטעמה, למצבו הפיסי של החניון, למטרדים, ועוד כהנה וכהנה. בחרתי, כאמור, להתמקד בעיקריות שבהן, ובאלו הנדרשות להכרעה במחלוקות לשם בחינת הזכאות לסעדים המבוקשים בכתבי התביעה.

ג. הסוגיות הנדרשות להכרעה

49. בהליך דנן, חלוקים הצדדים במספר סוגיות עיקריות - **האחת**, במנגנון לקביעת דמי ניהול ואחזקת הרכוש משותף, ובחובות הקיימים מכוחו. **השנייה**, בשימוש הנטען בתשתיות החשמל והמים המשותפות, ובאחריות לחוב הכספי הנגזר מכך. **השלישית**, בחניית רכבי די גיי בתחומי הרכוש המשותף או בתחומי שטחי המעבר, ובדמי השימוש להן טוענת הנציגות בגינן. **הרביעית**, בשימוש במשטחים כבחניות ובמחסנים כמשרדים, האם מדובר בשימוש חורג (האם בכלל מדובר בסעד שהוא בסמכות ערכאה זו), בשימוש סביר התואם את הוראות התקנון, ומה נפקות הקביעות לעניינינו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

50. לשם הכרעה בכל אותן סוגיות יש להידרש, בין היתר, לשאלות הבאות:

א. **בסוגיה הראשונה** - האם שיטת החישוב החדשה (כאמור ב"מכתב השינוי") עולה בקנה אחד עם הוראת התקנון המוסכם? האם העלאת דמי הניהול בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות נעשתה כדין, ואם כן - האם יש לה תוקף מחייב גם כלפי חליפיהם של בעלי הדירות בעת שהתקבלה ההחלטה? לאור תוצאת ההכרעה בשאלות דנן, יש להידרש לבחינת החוב הפרטני הנטען, של כל צד כלפי משנהו.

ב. **בסוגיה השנייה** - האם הוכח שימוש של די ג'יי או מי מטעמה בתשתיות החשמל או המים המשותפות, מה ידעה על כך די ג'יי בזמנים הרלוונטיים, ומה המשמעות הכספית של הממצאים בסוגיה זו.

ג. **בסוגיה השלישית** - היכן, אם בכלל, חונים רכבי אלדן ב"תחומי המעבר" (האם ברכוש משותף או בשטח בבעלות די ג'יי הכפוף ל"זיקת הנאה"), והאם זכאית הנציגות לדמי שימוש בגין חניות אלו.

ד. **בסוגיה הרביעית** - האם הסעד המבוקש הנוגע להכרה בשימוש שעושה די ג'יי בחניון כשימוש חורג, הוא בסמכות ערכאה זו, והאם ניתן לדון במבוקש במסגרת "סמכות שבגררא?". האם מדובר ב"שימוש סביר" על פי הוראת התקנון המוסכם, ומה נפקות הקביעה בעניין זה.

51. להלן אדרש לסוגיות ושאלות אלו, ראשון -ראשון ואחרון -אחרון.

ד. דיון והכרעה

ההחלטה בדבר שינוי שיטת החישוב של גביית דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף ("מכתב השינוי")

52. היחסים בין בעלי דירות בבית משותף מוסדרים על פי מספר מערכות של כללים: הוראות חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו על פיו, התקנון המוסכם או המצוי לפי העניין, החלטות האסיפה הכללית של הבית המשותף, החלטות נציגות והחלטות המפקח על רישום מקרקעין. ניתן לדמות את התקנון המוסכם או המצוי ל-"חוקה" של הבית המשותף, את האסיפה הכללית ל-"רשות מחוקקת" ואת הנציגות ל-"רשות מבצעת". כך, כשם שהרשות המחוקקת כפופה להוראות החוקה ואינה מוסמכת לחוקק חוקים המנוגדים לה, כך גם האסיפה הכללית איננה מוסמכת ליתן החלטות העומדות בסתירה להוראות התקנון, כל עוד לא שונה התקנון כדין.

על התקנון המוסכם כתב המלומד אריה אייזנשטיין (א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות בידיני מקרקעין**, חלק שלישי, עמ' 133) את הדברים הבאים -

"את התקנון המוסכם ניתן לרשום בפנקס הבתים המשותפים בדומה להסכם שיתוף. כל עוד התקנון לא נרשם, הריהו מחייב רק את בעלי הדירות שבאותה עת ואינו מחייב צד ג'. לעומת זאת, משנרשם התקנון בפנקס הבתים המשותפים, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן. הרישום, מעניק לתקנון תוקף קונסטיטוטבי - מעין קנייני, בכך שהוא מאפשר לכל אדם לעיין בו ולהסתמך עליו בבואו לעשות עסקה בדירה שהתקנון חל עליה. צד ג' הרוכש דירה שחל עליה תקנון שנרשם, אינו יכול לטעון שהתקנון אינו מחייבו, כשם שאינו יכול לטעון ששעבודים הרשומים לדירה, כגון זכות שכירות או משכנתא, אינם מחייבים אותו".



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

53. סעיף 62(א) לחוק קובע הוראות בנוגע לאופן שינוי התקנון המוסכם: "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

54. על אף מעמדו המעין "חוקתי" כאמור, התקנון גם נתפש כחווה, או למצער, כמוסד משפטי עליו חלים דיני החוזים. בע"א 5043/96 נחמיה גלמן נ' הררי רפול עזרא, פ"ד נד(3), 389, נקבע כי תקנון הבית המשותף הינו בגדר הסכם בין הצדדים, וככזה, מלאכת פרשנותו היא כמלאכת פרשנותו של חוזה.

55. כאשר עסקינן בפרשנותו של חוזה, עלינו לתת את הדעת הן ללשון החוזה והן לנסיבות כריתתו ולאומד הדעת הסובייקטיבי המשותף של הצדדים לחוזה: "אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה 'קבילים' הם. בעזרתם מגבש הפרשן את אומד דעתם המשותף של הצדדים" (דברי המשנה לנשיא (כתוארו אז) השופט ברק, ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, פ"ד מט(2) 265 (1995), בעמוד 311- להלן: "עניין אפרופים"). הלכה זו נתאשררה לאחר דיון בהרכב מורחב בדנ"א 2045/05 ארגון מגדלי הירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד סא (2) 1, 2006 (להלן: "ארגון מגדלי ירקות").

56. לאחר שנפסקו ההלכות בעניין אפרופים וארגון מגדלי הירקות לעיל, נחקק תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"). הוראת סעיף 25(א) לחוק החוזים קובעת כך:

"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו".

57. בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ (פורסם ב"נבו"), נדון תיקון מס' 2 לעיל, כאשר על רקע בחינת ההלכה הפסוקה, הגיע בית המשפט למסקנה כי בהליך פרשנות החוזה, ביקש המחוקק ליתן משקל משמעותי ללשונו-

"...עד כאן באשר לתכליתו הסובייקטיבית של סעיף 25(א) המתוקן. כפי שראינו, תכלית זו מצביעה בבירור על כך שהפירוש הנכון לסעיף המתוקן הוא כדלקמן: חוזה יפורש תוך בחינה מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל נסיבות העניין, בכפוף לחזקה פרשנית – ניתנת לסתירה – שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון, דהיינו: את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב. החזקה ניתנת לסתירה במקרים שבהם למד בית המשפט, מתוך הנסיבות, כי הלשון אינה פשוטה וברורה כפי שנחזתה להיות במבט ראשון; וכי למעשה – עשויה היא להתפרש בדרכים אחרות מאלה שנראו ברורות בתחילת הדרך הפרשנית. ודוק: קיומה של החזקה מבטא את משקלה החשוב והמשמעותי של לשון החוזה; לעומת זאת, היותה ניתנת לסתירה משקפת את העובדה כי משקלה של הלשון, חרף חשיבותה, אינו מכריע או בלעדי".



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

58. נוכח המקום המרכזי השמור ללשון החוזה בהליך הפרשני נפסק עוד כי "ככל שלשון החוזה ברורה יותר, כן תיזרשנה ראיות-חוץ בעלות משקל כבד יחסית כדי לגבור על הפירוש הנדרש ממנה לכאורה... מישקלן הכולל של ראיות-החוץ חייב שיהא רב למדי עד שיעלה בידיהן לגבור על הלשון הברורה" (ארגון מגדלי ירקות, פסק דינו של השופט חשין בעמ' 52-53).

59. נראה, אם כן, כי תיקון מספר 2 לעיל לא הביא, ככלל, לשינוי בהלכות פרשנות חוזים, במובן זה שהשיטה הפרשנית שהונהגה בעניין אפרופים ובעניין מגדלי הירקות לא חלפה כליל מן העולם. יחד עם זאת, לאור תיקון מס' 2, יש ליתן, לכל הפחות, ואף אם התיקון עצמו לא חל על ההסכם הנדון, מקום משמעותי ללשון החוזה במסגרת תהליך הפרשנות (ראה דיון מקיף שנערך בנושא במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 3894/11, דלק- חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' ניר בן-שלום (פורסם בתקדין. ניתן ביום 6.6.13).

60. ומן הכלל אל הפרט - פרשנותו של התקנון המוסכם שלפנינו.

61. כאמור, בכל הנוגע לאופן הנשיאה בהוצאות אחזקת וניהול הרכוש המשותף, קובע התקנון המוסכם בסעיף 7 כך:

" נקבע בזה בהתאם לסעיף 58 לחוק להלן:

בעלי יחידות המשנה, למעט יחידת משנה מס' 138/1, בבית המשותף יישאו בכל הוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף, לפי יחס שטח רצפתה של יחידת המשנה שבבעלותם לכלל שטח הרצפות של כל היחידות בבית המשותף, ללא השטח הצמוד לה בצמידות מיוחדת, למעט שטח ממ"ק שצמוד ליחידה או מהווה חלק ממנה שייווסף לשטח היחידה, ולמעט שטח מחסנים שאינם בקומות החנייה אשר ייווספו לשטח היחידה תוך הכפלה במקדם של 50% כמפורט בטבלה שלעיל. כמו כן יחידות המשנה המהוות ומשמשות מחסנים יישאו בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף בשיעור של 50%, מיחידות משנה שאינן מהוות ומשמשות למחסנים. יחידת משנה 138/1 תשלם 1 ₪ לשנה עבור הוצאות החזקה וניהול של הרכוש המשותף".

62. בסעיף 9.1 לתקנון המוסכם נקבע עוד כי:

"על כל בעלי יחידות המשנה להשתמש ביחידותיהם שימוש יעיל וסביר מתוך מתן הדעת על הצורך לאפשר ליתר הדיירים שימוש נאות ביחידותיהם, ברכוש המשותף ובדרכי המעבר. בפרט, חל איסור מוחלט על סתימת וחסימת דרכי המעבר ברכוש המשותף, ובמשטחים המפורטים בסעיף 6 לעיל ועל הרמת חפצים המונעים ו/או המפריעים לשימוש בהם".

(ההדגשות שלי- י.ע.ש).

63. הנה כי כן, בחינת לשונו הפשוטה והברורה של התקנון מעלה כי ככלל, שטחן של צמידויות מיוחדות לא ייכלל במניין "שטח רצפת הדירה", לשם חישוב חלקה של הדירה בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף. החרג שנקבע בתקנון לכלל זה הוא שטח ממ"ק, ושטחי מחסנים, אשר אינם בקומת החנייה, אשר יישאו בשיעור 50% מיחידות משנה שאינן מהוות ומשמשות למחסנים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

64. על פי צו הבית המשותף, המשטח מהווה, כאמור, צמידות מיוחדת לתת חלקה 31. לפי אותו צו, המחסנים, שאף הם צמודים לחלקה 31, נמצאים בקומת החניון. לפיכך, על פי לשונו הפשוטה והברורה של סעיף 7 לתקנון המוסכם- אין לחשב את שטחי המשטח והמחסנים בקומת החניון כחלק משטח הדירה לשם נשיאה בהוצאות אחזקת וניהול הרכוש המשותף. מובן, גם, כי לפי לשון התקנון אין לראותם כ"דירה" נפרדת.
65. בהקשר זה יש לציין כי סעיף 9.1 לתקנון המוסכם אמנם קובע כי על כל בעלי היחידות לעשות שימוש יעיל וסביר ביחידותיהם, אולם אין בו הוראה מפורשת לפיה ככל שלא יעשה שימוש כזה, יש בכך בכדי לשנות את מנגנון חישוב הנשיאה בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף.
66. האם, על אף לשונו הברורה של התקנון, יש בבחינת תכלית התקנון ואומד דעת הצדדים בכדי ללמד על כוונה אחרת? נפנה עתה לבחינת סוגיה זו.
67. אקדים ואציין כי כללי הפרשנות המוכרים לצורך בחינת אומד דעת הצדדים, עת עסקינן בחוזה שנערך בין צדדים, פשוטים יותר ליישום עת מדובר בצדדים לחוזה, אשר ניתן לברר מעדויותיהם וממסמכים אחרים שבידיהם, את אומד דעתם טרם כריתת החוזה ואף במהלכו. עת נדונה פרשנותו של תקנון מוסכם, מלאכה זו עשויה להיות מורכבת יותר, שכן פעמים לא מעטות נרשם התקנון המוסכם כאשר לבית המשותף כולו בעלים אחד (כך למשל, מדינת ישראל או יזם אשר רכש את הקרקע במלואה ובנה עליה בית דירות). לפיכך, ככלל, הסכמת אותו בעלים יחיד לרישום התקנון המוסכם- די בה, שכן הוא המופיע בפנקסי המקרקעין כבעל המקרקעין בשלמותו, ולפיכך הסכמתו מהווה את הסכמת כלל הבעלים כדין.
68. במקרה בו קיימות הערות אזהרה, הרי שנדרש לוודא כי רישום הבית המשותף אינו פוגע בזכויות מוטבי הערות האזהרה, כאשר ככלל, ניתן להסתפק בתצהיר עורך הדין אשר ערך את חוזי המכר בדבר ייחוד ההערות האזהרה (ראה הוראת הנוהל 1.8.2121, לקובץ נוהלי רישום והסדר מקרקעין בהוצאת ועד מחוז תל אביב-יפו, לשכת עורכי הדין). ביסוד חלופה זו מונח, כי עורך הדין מכיר את חוזי המכר, ומודע לזכויות רוכשי הדירות בבית המשותף, ועל כן ניתן להסתפק בהצהרתו, כתחליף לאישורי מוטבי הערות האזהרה. במקרים מסוימים, ניתן להסתפק בהצהרת עורך דין שבדק את החוזים, ולא דווקא זה שערך אותם.
69. המקרה הנדון הוא מקרה דומה למתואר לעיל, שכן התקנון המוסכם נרשם בעת שחברת עומר אלבז הייתה בעליו הרשומים הבלעדיים של המקרקעין בשלמותו (בכפוף להערות אזהרה שונות). לפיכך בקשתה לרישום התקנון המוסכם היוותה, בעת הגשתה, את הסכמת כלל בעלי הדירות הרשומים. עם זאת, מעיון בתיק הפעולה של רישום הבית המשותף (20443/2006) עולה עוד כי אף הוגשו הסכמותיהם **האישיות** לייחוד הערות האזהרה כמבוקש של רוב מוטבי הערות האזהרה ועבור מיעוטם הוגש תצהיר עורך דין בנוגע לייחוד הערות האזהרה על דירות פרטניות.
70. מכאן יש להסיק כי לא הועלתה כל טענה או התנגדות של מוטבי הערות האזהרה לרישום הבית המשותף באופן המבוקש.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

71. יש לציין ברקע הדברים כי חוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 (להלן: "**חוק המכר**"), מחייב את מוכר הדירה לכלול במפרט או לצרף לחוזה פרטים הנוגעים לשינוי שיש בתקנון המוסכם שחל או שנועד לחול על הבית, מהוראות התקנון המצוי. הוראת סעיף 6 לחוק המכר קובעת בהקשר זה כך-

"(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן הענינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין; ואלה הענינים:

(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;

(2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;

(3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחוייבים בקשר אליו;

(4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;

(5) כל ענין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמורה בסעיף 3(א).

(ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהענינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף.

(ג) המונחים בסעיף זה ובסעיף 6 יפורשו לפי משמעותם בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969."

72. לפיכך, חזקה היא (ולא נטען בפני אחרת) כי בעת שמכרה חברת עומר אלבז דירות בבית המשותף, היא צירפה לחוזה או למפרט את הוראות התקנון המוסכם שיש בהן כדי לשנות מהוראות התקנון המצוי, ואף פירטה במסגרת זו את שיעור החלקים ברכוש המשותף אשר הוצמדו לדירה מסוימת ואת שיעור ההשתתפות בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף. על כן, מוחזקים גם רוכשי הדירות, בין אם היו בעת רישום הבית המשותף מוטבי הערות אזהרה אשר הגישו הסכמתם לייחוד דירות ובין אם עמדה לזכותם רק זכות אובליגטורית בלתי רשומה, כמי שידעו וקיבלו על עצמם את הוראות התקנון המוסכם, את שיעור החלקים אשר הוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות ואת שיעור ההשתתפות בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף.

73. אפנה, אם כן, לבחינת אותם **מטרות, יעדים, ואינטרסים אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים**.

74. התקנון המוסכם מבדיל, כאמור לעיל, בין יחידות משנה לבין צמידויות. סעיף 55(ב) לחוק קובע כי: "**עסקה בדירה תחול גם על החלק ברכוש המשותף הצמוד אליה, ואין תוקף לעסקה ברכוש המשותף בנפרד מן הדירה...**" בסיפא לסעיף 55(ג) לחוק נקבע כי: "**הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה אליה הוצמד**".

75. מר אמנון בראשי, מנהל חברת עומר אלבז השקעות בע"מ (להלן: "**בראשי**"), העיד כי הוא זה שהניע את רישום התקנון המוסכם, בעזרת עו"ד מיכאל שטיינר ורונית אדהן. על פי עדותו, בזמן רישום התקנון לא הייתה מצדו כל התנגדות לשימוש כלשהו שיעשה בשטחי החניון, לרבות המשטחים, ולא הייתה מניעה מבחינתו כי יעשה במשטח כל שימוש שהוא. כשנשאל לסיבה בגינה נרשם חלק ניכר מהחניון כ"משטח" ולא כ"חניות" הסביר כי- "**בגלל שאם היינו רוצים לא לעשות את זה לשימוש כחנייה אלא לשימוש אחר אז לא**



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

רצינו להגדיר את זה מראש לחניות, למשל אם היה בא מוסך שם היינו נותנים לו" (ראה פרוטוקול מיום 10.11.13, עמ' 8 שורות 33-34).

76. בראשי לא נחקר ביחס לסיבה בגינה הוחלט על ניסוח סעיף 7 לתקנון כפי שהוא, היינו כי החיוב בדמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף יהיה לפי שטחי הדירות, ללא שטחי הצמדות מיוחדות. עם זאת הוא הבהיר כי גם קביעה זו נעשתה בידיעה שבמשטחים (שהם, כידוע, צמידות מיוחדות של חלקות משנה מסוימות) יכול ויעשו שימושים שונים, בין אם לצרכי חניה, מוסך ואחרים, ואף על פי כן הוחלט על ניסוח התקנון כפי שהוא.
77. מלבד לבראשי, לא העידו הצדדים עדים נוספים אשר היו מעורבים בניסוח התקנון או ברישומו, ולפיכך מעבר לעדות זו לא נשפך אור על נושא זה.
78. מכאן עולה, למעשה, כי טענתה המשתמעת של הנציגות לפיה בקבעו כי אין לכלול את שטחי ההצמדות בחישוב שטח הדירה לשם חישוב חלקה בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, לא התכוון מתקין התקנון המוסכם כי יעשה בהצמדות שימוש מסחרי כלשהו, נסתרה בעדותו של בראשי ולא נתמכה בכל ראיה או עדות אחרת מטעם הנציגות. כך למשל, הנציגות לא העידה אף אחד ממי שהיו מוטבי הערות אזהרה בעת רישום הבית המשותף (מצו הבית המשותף עולה כי מדובר ב-24 רוכשי יחידות), ולפיכך לא נשמעה כל עדות התומכת בטענתם כי בעת רישום הבית המשותף אומד דעת בעלי הזכויות ובכללם מוטבי הערות האזהרה הייתה שונה מזו המשתמעת מלשון התקנון כפשוטו.
79. מסקנתי היא אפוא כי פשט הלשון של התקנון לא נסתרה ולא נסדקה מהראיות והעדויות שהוצגו בהליך זה, ולפיכך יש ליתן לה את מלוא כובד המשקל בהליך פרשנותו של התקנון המוסכם. סעיף 7 לתקנון קובע בצורה ברורה כי צמידויות מיוחדות לא תכללנה בחישוב שטח הדירה (למעט אלו המוזכרות שם במפורש כגון ממ"ק ומחסנים), ולפיכך אין לחשב את שטחי הצמידויות, כגון החניות והמשטח כחלק משטח הדירה לצורך חישוב חלקה של יחידת המשנה בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף. מקל וחומר שאין לחשב את הצמידויות כ"דירה/ יחידת משנה" בפני עצמה.
80. הטענות כי בפועל נעשים במשטחים ובחניות שימושים שאינם שונים משל כל עסק אחר בקומות העליונות של הבית המשותף, שימושים אשר לטענת הנציגות אף מרעים ומזיקים לבעלי הדירות, אין בהן די כדי להוביל לפרשנות שונה של התקנון. אף אם הדבר מצדיק פעולה במישורים משפטיים אחרים (ואינני קובעת בעניין זה דבר), אין בכך בכדי להוביל למסקנה כי מהתקנון, הקובע ברחל בתך הקטנה כי שטחי צמידויות אלו לא יכללו בחישוב שטח הדירה לצורך תשלומי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, עולה כי יש להכלילם בחישוב זה. ודוק: הטענה אינה כי יש להכלילם בחישוב שטח הדירה, אלא כי יש לערוך לגביהם חישוב נפרד, משל היו הצמידויות ליחידת משנה עצמאית ונפרדת. טענה זו היא מרחיקת לכת (במיוחד שעה שאין מדובר בבנייה של יחידה כלשהי בחניון כי אם בשימוש בחניון כפי שהוא, למטרות חנית רכבים) ועומדת בסתירה להוראותיו המפורשות של התקנון המוסכם.
81. ודוקו: אף אם יש צדק בכך שעל העושים שימוש בחניות לשלם עבור אחזקתן, שכן הם נהנים משירותי אחזקה אותם מממנים בעלי הדירות (ראה סעיף 6 להוראת התקנון המוסכם), אין בכך די בכדי לשנות את



משרד המשפטים לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין ירושלים

הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף. לשם קביעת שיטת חישוב השונה מזו הקבועה בתקנון המוסכם, יש לפעול לשינוי הוראותיו וזאת על פי הוראות הדין. כל עוד לא נעשה הדבר, לא ניתן לשנות את הוראות התקנון המפורשות בדרך אחרת, אף אם יש בסיס צודק והגיוני לשינוי זה.

82. בסיכומיה טענה הנציגות כי התקנון בטל, בשל פגמים שונים שנפלו לשיטתה בהליך רישומו. אינני נדרשת לטענה זו ולו משום שהיא לא עלתה בכתב ההגנה או בכתב התביעה שכנגד ויש בכך משום הרחבה ושינוי חזית אסורים. מעבר לכך, ממילא אין בסמכותה של המפקחת על רישום מקרקעין להידרש, במסגרת הליך משפטי המתנהל בפניה, לביטול תקנון וזאת יש לעשות על פי הוראות הדין. למעלה מן הצורך ומבלי לקבוע בכך מסמרות אציין עוד כי מהחומר המונח בפני לא מצאתי בטענות ממש גם לגופו של עניין, ונראה לכאורה כי אלו אינן עולות בקנה אחד עם תוכנו של תיק הפעולה הנוגע לרישום הבית המשותף.

83. הנה כי כן, החישוב המבוקש על ידי הנציגות, ולפיו יש לחייב את שטחי הצמידויות לפי השימוש שנעשה בהם בפועל, משל היו יחידה עצמאית (כאמור במכתב השינוי) – איננו תואם את הוראות התקנון המוסכם.

האם העלאת דמי הניהול בהחלטת האסיפה הכללית היא כדי להחייב את די ג'יי?

84. בקביעה כי ההחלטה המעוגנת במכתב השינוי איננה תואמת את הוראות התקנון המוסכם – אין די. יש להמשיך ולהידרש לשאלה האם החלטה בדבר שינוי שיטת החישוב התקבלה במסגרת האסיפה הכללית או בהסכמת קודמה של די ג'יי, וככל שהתשובה חיובית – האם מדובר בהחלטה בעלת תוקף נורמטיבי המחייב את די ג'יי.

85. כאמור, אחת ממערכות הכללים החלות על בעלי דירות בבית משותף, היא החלטות האסיפה הכללית. סעיף 5 לתקנון המצוי קובע כי "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". החלטות מסוג זה, די אם יתקבלו במסגרת האסיפה הכללית ברוב דעות (ראה סעיף 12 (א) לתקנון המצוי).

86. לא כך כאשר האסיפה הכללית מבקשת לשנות סעיף תקנוני. במצב דברים זה, עליה לעמוד במגבלות הקבועות בסעיף 62(א) לחוק, הקובע, כאמור, כי –

" בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם..."

87. בדומה, קובע גם סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי:

" החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה – אלא אם הסכים לה."

88. הנה כי כן, האסיפה הכללית איננה יכולה ברוב דעות לקבל החלטה שמשמעותה שינוי סעיף תקנוני. על מנת לקבל החלטה כזו, יש לגייס את הסכמת רוב בעלי הדירות ששני שלישי מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. בנוסף לכך, כאשר מדובר בהחלטה המשנה את התקנון ויש בה משום שינוי זכויות או הטלת תשלומים



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק - נדרשת בנוסף גם הסכמה מפורשת של בעלי הדירה שזכויותיהם ישתנו בעקבות קבלת ההחלטה.

89. לעניין זה יפים דבריו של המלומד מ. דויטש בספרו (מ.דויטש, קניין, כרך א', עמ' 736 - להלן: "**דויטש**"):
"**כוחה של האסיפה הכללית מצוי ברמה היררכית נמוכה יותר מכוחו של התקנון. סמכותה של האסיפה יונקת מן התקנון (המצוי או המיוחד - לפי העניין) וכפופה לו. גם חוג העניינים אשר מצויים בסמכותה של האסיפה הכללית הוא בהכרח צר יותר, מאשר הסמכות של בעלי רוב של שני שלישים לשינוי התקנון. גבולות הכוח לעניין זה, בדומה לגבולות הכוח בקביעת הוראה תקנונית, הם עמומים וכוללניים, אך יש להיות ערים להבדל ההיררכי בין שני סוגי הנורמות**".

90. בהתאם לכללים אלו, נקבע בסעיף 71 (א) לחוק, הדן בנסיבות בהן תחייב החלטת האסיפה הכללית את מי שהפך לבעל דירה לאחר קבלתה, כי תנאי לחיוב מסוג זה הוא כי מדובר, בין היתר, בהחלטה "**שנתקבלה בהתאם לתקנון**".

"**החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה**" (ההדגשה שלי - י.ע.ש).

91. לשון אחר: על מנת שהחלטת האסיפה הכללית אשר נרשמה בספר ההחלטות תחייב בעל דירה שהפך לכהן לאחר קבלתה, צריכה להיות זו החלטה **שהתקבלה בהתאם לתקנון**. בכדי להעניק תוקף להחלטה שיש בה משום **שינוי תקנון** אין די כי תתקבל באסיפה הכללית, אף אם פורסמה בספר ההחלטות. עצם הפרסום בספר ההחלטות איננו מקנה לה את תוקפה המחייב. עת מדובר בהחלטה שמשמעותה שינוי סעיף בתקנון, תוקפה המחייב מתגבש רק עת החלטה זו התקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. ככל שיש בה שינוי זכויות או הטלת חיוב כספי מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק - גם בהסכמת בעלי הדירות שזכותם משתנה בעקבותיה.

92. כאשר עסקינן בהחלטה שהתקבלה בהתאם לתקנון, הרי שאם נרשמה **בספר ההחלטות** "היא תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה" כקובע בסעיף 71 לחוק. המלומד דויטש קובע כי ניתן לראות את "ספר ההחלטות" כ- "**רישום סדור כלשהו של פריטיכלים של החלטות**" (מ. דויטש, קניין, כרך א', בעמ' 741, ה"ש 241).

93. זאת ועוד. במקרים מסוימים נפסק כי בעל דירה יהיה מחויב להסכמת קודמו אם ימצא כי **ידע על קיומה**, גם אם טרם ניתן לה ביטוי במרשמים הפומביים (ראה: ע"א 815/81, **כליפא נ' שאול**, לו (3) 78, (ע"א חיפה) 1020/03, **בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף**, תק-מח 2004(1), 5244). מקל וחומר כי הדברים נכונים ביחס להחלטת בעלי הדירות שיש בה משום שינוי תקנון, ושבעל הדירה פעל על פיה.

94. לשון אחר: כאשר התקבלה החלטה המטילה על בעלי הדירות חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק ואין להם עיגון בתקנון המוסכם, החלטה זו תהיה בעלת תוקף נורמטיבי מחייב רק אם התקבלה ברוב בעלי הדירות ששני שלישי מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, וכן ניתנה לה הסכמתו



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

המפורשת של בעל הדירה שזכויותיו ישתנו בעקבות קבלת אותה ההחלטה. ככל שההחלטה עומדת בתנאים אלו, אולם טרם ניתן לה ביטוי רשמי בתקנון המוסכם, היא תחייב בעל דירה שבא בנעלי מי שהיה בעל דירה בעת קבלת ההחלטה, אם פורסמה בספר ההחלטות של הבית המשותף או אם אותו בעל דירה "חליף" ידע עליה ונהג על פיה הלכה למעשה.

95. העובדה כי החלטה שכזו מהווה, למעשה, שינוי של תקנון, משמעה, בין היתר, כי אין בעל הדירה אשר פעל בהתאם לה זכאי לחידול מ"הסכמתו שבהתנהגות" ולחזור למצב המעוגן בתקנון המצוי או המוסכם לפי העניין (בהנחה, כאמור, שהתקנון המוסכם טרם שונה בתיק הבית המשותף במרשם המקרקעין בעקבות קבלת ההחלטה). חזרה שכזו מהתנהגות בפועל אפשרית כל עוד מדובר בנוהג, או בהחלטת אסיפה כללית אשר התקבלה ברוב רגיל ואין בה כדי להוות שינוי תקנוני (על אפשרות החזרה מההסכמה במקרה האחרון ראה למשל: ע"א (חיפה) 1688/00, **נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' בלהה (בילי) ברוך ואח'**, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 4.3.02) וכן עשא (חיפה) 29972-12-12 **אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב המגינים 53** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 8.4.13).

מן הכלל אל הפרט

96. יש להידרש עתה באופן פרטני להחלטה שהיא נושא מכתב השינוי ולהחלטת האסיפה הכללית מיום 20.2.08 (להלן: **"החלטת 2008"**, ראה נספח 3 לתצהיר ראובן חי כהן (להלן: **"חי כהן"**) מטעם הנציגות).

97. הנציגות טענה כי החלטתה שהיא נושא "מכתב השינוי" תואמת **החלטה אחרת**, מוקדמת, שקיבלה בעבר **האסיפה הכללית**, ועל כן היא תקפה. בכך מכוונת הנציגות להחלטת 2008. בהחלטת 2008 התקבלו ממספר החלטות, פה אחד-

"א. עד ליום 30.4.08 יחולו דמי הניהול לפי הסכומים והתנאים הבאים:

א.1 יופחת סכום הניהול לגבי הבניין ויועמד על סך חודשי של 10 ₪ למ"ר.

א.2 חיוב דמי האחזקה והניהול בעבור כל חנייה בחניון, יעמוד על סך של 65 ₪ לחודש.

ב. החל מתאריך 1.5.08 תבוטל השמירה בכניסה לחניון.

ג. החל מתאריך 1.5.08 יוקטן חיוב דמי האחזקה והניהול, עבור כל חניה ל-45 ₪ לחודש.

ד. חב' "אלדן" תתקין, על חשבונה, מונה חשמל נפרד לצורך צריכת החשמל שלה בחניון, והיא תישא (רטוראקטיבית) גם בסכום צריכה מוערך, כלפי העבר, בגין שימושה באספקת-החשמל המשותפת של הבניין."

98. מפרוטוקול אסיפה הכללית בה התקבלה החלטת 2008 עולה כי מר אילן אורנשטיין, נציג קבוצת אורנשטיין (לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי אורנשטיין היה בעת הרלוונטית בעליה של חלקת משנה 8- ראה למשל השלמת הטיעון מטעם הצדדים מהימים 9.9.14 ו-10.9.14), וכן אמנון בראשי, אשר היה בזמן זה נציג חב' עומר אלבז, בין היתר בעלי תת חלקה 31 על צמידויותיה (בהתאם לאמור בנסח ההיסטורי), הסכימו ל"הפרדת התקציב". משמעות הפרדת התקציב היא כי תהיה הבחנה והפרדה בין תקציב לאחזקת הבניין ולבין תקציב לאחזקת החניון. בסופה של אותה אסיפה הוסכם, כאמור, על דעת כל הנוכחים בה, לרבות אורנשטיין ובראשי, כי יופחת סכום דמי הניהול עבור הבניין, כאשר במקביל יגבה מכל חניה סך של 45 ₪ לחודש.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

99. מעיון ברשימת הנוכחים באסיפה הכללית שנערכה ביום 20.2.08 אל מול הנסחים הרלוונטיים, עולה כי החלטה זו התקבלה על ידי רוב בעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף היה צמוד לדירותיהם אותה עת. לפיכך, **מדובר בשינוי הוראה תקנונית מחייבת**. אפרט.
100. בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 20.2.08 (נספח 3 לתצהיר חי כהן) מפורטת רשימת המשתתפים בה. מהשלמת הטיעון של הצדדים (מהימים 9.10.14 ו-10.9.14) עולה כי הם חלוקים בשאלה האם החלטה זו התקבלה ברוב של בעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. בעוד שהנציגות טענה כי החלטה זו התקבלה על ידי 11 בעלי דירות או נציגיהם אשר למעלה מ-75% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, טענה די גיי כי ההחלטה התקבלה, לכל היותר, בידי 7 בעלי דירות ש-46% בלבד מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
101. שני הצדדים הסכימו כי ניתנה הסכמת בעלי הדירות הבאות: **ביטוח לאומי** (חלקת משנה 13, לה 72/767 חלקים מהרכוש המשותף), **קבוצת אורנשטיין** (חלקות משנה 8 ו-31, אשר 55/676 חלקים צמודים לדירותיהם), **גדעון ניסן** (בעל חלקת משנה 20, אשר 19/676 חלקים מצודים לדירתו), **ניסים שוקר** (בעלי חלקות משנה 17 ו-18, אשר 24/676 חלקים צמודים לדירותיו), **עומר אלבו בע"מ** (בעלי חלקות משנה 1,2,3,4,5,9,31, אשר 81/676 חלקים צמודים לדירותיו), **סטיב אכסקליבור** (בעלי תת חלקה 29 אשר 55/676 חלקים צמודים לדירותו), **ונתן כהן** (בעלי חלקת משנה 25, אשר 9/676 חלקים צמודים לדירתו). עד כאן יוצא כי אין מחלוקת כי בעלי דירות אלו, לדירותיהם צמודים ביחד 46% מהרכוש המשותף, נתנו הסכמת להחלטת 2008.
102. המחלוקת נוגעת למעשה למשמעות הסכמתם של בעלי 4 משתתפים נוספים באסיפה- עו"ד מיכאל הכסטר, רמי נגר וניר ששתיאל, אברהם סנפירי, וגואל שחר.
103. הנציגות טענה כי עו"ד הכסטר הוא נציג בעלי תת חלקה 10 לה 6/676 חלקים ברכוש המשותף, רמי נגר וניר ששתיאל הם נציגי "ניביט", לכאורה בעלי חלקת משנה 11 לה 43/676 חלקים ברכוש המשותף, אברהם סנפירי הוא נציג "אידע", בעלת חלקות משנה 14 ו-21, להן יחד 71/676 חלקים ברכוש המשותף, וגואל שחר הוא נציג "א.ד.ג" בעלת חלקת משנה 28, לה 23/676 חלקים ברכוש המשותף.
104. די גיי טענה מצדה כי אותם נציגים אינם רשומים כבעלי חלקות משנה בנסח כלל ואף אין לטובתם הערה בנסח ולפיכך מעמדם לא ברור ואין למנות אותם במסגרת מקבלי ההחלטות.
105. אמנם, צודקת די גיי בטענתה כי נציגים אלו אינם רשומים במרשם המקרקעין כבעלים או כמוטבי הערות אזהרה. אולם, עדות שנשמעה מטעם די גיי מלמדת כי אלו אכן היו בעלי דירות או נציגיהם המוסמכים. מר בראשי, אשר העיד כאמור מטעמה של די גיי, אישר בחקירתו כי באסיפה זו אכן נכחו 11 בעלי דירות או נציגיהם: "ש. ממה שאתה רואה בפרוטוקול כמה זיירים היו? ת. חוץ מניר סשתיאל שהוא שוכר, אבי קושניר שייך לחברת הניהול... 11 בעלי יחידות או נציגיהם" (ראה פרוטוקול הדיון מיום 10.11.13, עמ' 6 שורה 3).



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

106. יתרה מכך. גם לאורך סיכומיה חוזרת די ג'יי, על הטענה כי ההחלטה התקבלה על ידי 11 בעלי דירות, וזאת על אף שמספר הנפשות שנכחו באסיפה גדול מ-11 (ראה למשל: סעיף 16 לסיכומי התשובה של די ג'יי- "...**על שהוחלט על ידי 11 דיירים בלבד**...", סעיף 13 לסיכומים – "**נערך בנוכחות 11 דיירים בלבד**...").
107. ואומנם, הנציגות טענה כי החלטה זו התקבלה על ידי 11 בעלי דירות או נציגיהם (ראה בהשלמת הטיעון מטעמה מיום 9.9.14) ומכאן שיש לראות גם באותם "נציגים" ככאלו אשר הוסמכו להצביע באסיפה בשם שולחיהם. לפיכך קיים רוב של בעלי הדירות שלמעלה מ-75% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
108. ודוק: מדובר ב-11 אנשים המייצגים בעלי דירות, אולם לחלקם, כאמור לעיל, מספר דירות (כך למשל, עומר אלבו, אורנשטיין). בדיקת מספר הדירות שהיו מיוצגות באסיפה מעלה כי אכן הייתה נוכחות של רוב בעלי הדירות או נציגיהם.
109. אעיר כי אף אם הייתי מקבלת את טענת די ג'יי לגבי נציגים של חברות שכלל לא מופיעות בנסח, הרי שהדברים נכונים ביחס למיכאל הכסטר וכן לרמי נגר וניר ששתיאל (נציגי "ניביט" לכאורה) שאף החברה שנטען כי הם שלוחיה אינה רשומה במרשם המקרקעין. לא כך לגבי אברהם סנפירי (אשר נטען כי הוא מיצגה של חברת "אידע החזקות" (1996) בע"מ" אשר הייתה בעת קבלת החלטת 2008 בעלת הערת אזהרה על פי הרישום בנסח ההיסטורי ולאחר מכן נרשמה כבעלי יחידות משנה 14 ו-21), ולגבי גואל שחר (על פי הנטען נציג "א.ד.ג. נכסים והשקעות בע"מ" אשר גם הייתה רשומה בעת הרלוונטית כמוטבת הערת אזהרה, ולאחר מכן כבעליה של יחידת משנה 28). גם חישוב זהיר, בהעדרם של הכסטר ונציגי "ניביט", מוביל לרוב של בעלי הדירות אשר 68% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, ודי בכך בכדי לעמוד בהוראות סעיף 62 (א) לחוק לשם שינוי התקנון המוסכם.
110. זאת ועוד. העובדה כי די ג'יי פעלה במשך השנים בהתאם להחלטה זו, והלינה עליה רק בעקבות מכתב השינוי (אשר כאמור עיגן החלטה שונה לחלוטין מהחלטת 2008), מחזקת את המסקנה כי אף היא ראתה בהחלטה זו במשך השנים ככזו אשר התקבלה כדין. בהקשר זה קיימת חשיבות גם לנאמר במכתב שושני המצדיק לגופה גם את ההחלטה בדבר הפרדה החשבונית: "**עניין העלויות יוסדר, כפי שהוסדר בעבר, באמצעות קביעת דמי ניהול בגין חניות**..."
111. יש לציין כי ההחלטה התקבלה בהסכמת קודמיה של די ג'יי (קבוצת "אורנשטיין" ו"עומר אלבו"), כך שמתקיימת גם הוראת סעיף 62(א) סיפא לעניין זה, הדורשת כי להטלת "החובות או התשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בתקנון" תתקבל הסכמת בעלי הדירות שזכויותיהם משתנות בעקבות אותה ההחלטה.
112. היות ומדובר בהחלטה שהתקלה בהתאם לתקנון, הרי שאם פורסמה בספר החלטות, יש בה כדי לחייב את מי שהפך לבעל דירה לאחר קבלתה.
113. שוכנעתי כי פרוטוקולי האסיפה הכללית, לרבות זה הנוגע להחלטת 2008, פורסמו בספר החלטות, לכל הפחות בגרסה המרוככת שלו, כעמדתו של המלומד דויטש. במקרה הנדון, מחומר הראיות שהוגש עולה כי אכן בידי הנציגות רישומים סדורים של החלטות האסיפה הכללית (חלקן הועבר לדי ג'יי במסגרת הליך גילוי מסמכים), באופן העונה לדרישת קיומו של אותו "ספר החלטות" (כך ראה למשל נספחים ד' ו-ה' לכתב



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

ההגנה- פרוטוקולי אסיפת דיירים מיום 20.1.08, נספח ו'- פרוטוקול החלטת 2008). החלטת 2008, לצורך העניין, מהווה חלק מאותם פרוטוקולים והחלטות סדורים השמורים בידי הנציגות.

114. מכל מקום, די גיי מחויבת להסכמת קודמיה, שכן ידעה על החלטת 2008, המהווה כאמור שינוי לתקנון, ואף פעלה לפיה. למעשה, אין חולק כי די גיי עצמה התנהלה בהתאם לקביעות שהתקבלו בהחלטה זו, במשך השנים.

115. טענת די גיי לפגמים שנפלו כביכול בהליך קבלת ההחלטה, שכן בעלי הדירות לא חתומים עליה ואף לא העידו בהליך- דינה להידחות. ככל שסברה די גיי כי מדובר בפרוטוקול שאינו משקף את שהוחלט באסיפה המתועדת בו, היה עליה לזמן את בעלי הדירות שנכחו בו, או למצער חלקם, על מנת שאלו יעידו כי ההחלטה לא התקבלה על דעתם כנטען. די גיי לא עשתה כן ובמצב דברים זה, אי העדת עדים אלו פועלת לחובתה.

116. לפיכך, די גיי מחויבת להסכמת קודמיה בהסתמך על החלטת 2008.

117. לא כך באשר להחלטה שהיא נושא "מכתב השינוי". כאמור לעיל, החלטה זו שמשמעותה שינוי דרמטי של אופן החישוב, גם ביחס לזה עליו הוחלט בהחלטת 2008, התקבלה על ידי הנציגות בלבד, וזו לא הייתה מוסמכת לקבלה (במכתב השינוי הבהירה הנציגות כי ההחלטה **לשנות את אופן החישוב** כאמור במכתב זה היא החלטתה **שלה**- "עקב הסדרת רישום היחידות בטאבו החליטה נציגות הדיירים..."). (ההדגשה שלי- י.ע.ש)). אין מדובר כלל בהחלטה התואמת את החלטת 2008, כי אם בקביעת כללי חישוב שונים לחלוטין. הנציגות לא טענה, וממילא לא הובאו ראיות לכך, כי להחלטה פרטנית זו **ניתנה** הסכמת די גיי. מובן, כי אם האסיפה הכללית אינה מוסמכת לקבל החלטה המנוגדת להוראת התקנון אלא במגבלות סעיף 62 לחוק, קל וחומר שהנציגות, הנמצאת במעמד היררכי נמוך משל האסיפה הכללית, אינה יכולה לקבלה.

118. **סיכומו של דבר, אין בהחלטה שהיא נושא מכתב השינוי בכדי לחייב את די גיי. באשר להחלטת 2008 - הרי שהיא מחייבת את די גיי.**

119. התוצאה היא כי די גיי איננה זכאית לקבל החזר בגין "כספים ששילמה ביתר", שכן הסכומים ששולמו על ידה בעבר נעשו בהתאם לקביעות החלטת 2008, שיש בהם משום שינוי תקנון.

סכומי החוב

120. בכתב התביעה שכנגד נטען כי לדי גיי חוב עבור השנים 2008-2012 העומד, לשיטת הנציגות, על סך כולל של 349,933 ₪. חוב זה, לטענת הנציגות, מורכב מיסודות שונים, ביניהם: חוב בגין שטח שירותים אשר סופח לחברת ביקור רופא, חוב עבור 20 חניות של מצרי, חוב עבור 58 חניות של אלדן (יוער בהקשר זה כי לפי נספחי תצהירו של רואה חשבון דוד פרנקל- להלן "**פרנקל**", "קפץ" החוב הנטען לפי כמות של 100 חניות לאלדן) חוב עבור 66 מ"ר משרדים בחניון 1- , וחוב עבור "ממ"ד בו השתמשה חב' פון ליי".

121. ביחס לחוב בגין שטח השירותים- לא הוכח הבסיס לקיומו של חוב כזה. מר אסף אבירם, מטעם די גיי (להלן: "**אבירם**"), האחראי על הקשר בין שוכרי הנכסים של די גיי לבין חברת הניהול, העיד כי "**די גיי מעולם לא סיפחה חדר שירותים די גיי שוכרת שטח שבו היא מעמידה לרשות דיירי הבניין שירותים**



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

חלופיים בהסכמת נציגות הבניין, כל פעם שדי ג'יי קיבלה דרישת תשלום לדמי ניהול עבור השירותים החלופיים התשלום בוצע במלואו... עדותו של אבירם הייתה מהימנה עלי, מה גם שהיא נתמכה בנספחים 11 ו-21 לעדותו. מנגד, הנציגות לא הראתה על מה מבוסס חוב זה ולא הוכיחה כי די ג'יי, או מי מטעמה, לא עמדו בדרישות תשלום אשר הופנו אליה, ככל שהופנו, ביחס לאותו חדר שירותים.

122. לגבי חניות מצרי ואלדן – לפי הנטען בכתב התביעה שכנגד, מבוסס חוב זה על התחשיב אשר צורף כנספח ט' לכתב ההגנה. על פי אותו נספח ט', החוב עבור החניות, הן של אלדן והן של לי, מתייחס ל-78 חניות. בניגוד לכך, בתחשיב של פרנקל אשר צורף לתצהירו, מחושב החוב לפי 120 חניות בסך הכל. מובן, כי גם סכום החוב "קפץ" פלאים מהמבוקש מכתב התביעה ועד לנטען בתחשיב אשר צורף לתצהיר פרנקל. מכל מקום, שוכרי די ג'יי קיבלו דרישות תשלום בפועל עבור 120 חניות (100 של אלדן ו-20 של פון לי/מצרי). לא הוכח כי חוב זה בגין החניות (אשר כאמור יסודו הוא בהסכמת אורנשטיין ובראשי ולאחריו בהסכמת די ג'יי) לא שולם כסדרו. בהקשר זה עדותו של אבירם לפיה הוא גובה מאלדן דמי ניהול "לפי התחשיב שהכרתי מיום שדי ג'יי רכשה את הנכס שהוא 9.6 ₪ לכל מטר רבוע עבור המשרדים ובשנים האחרונות 44 ₪ לחניה, למיטב זכרוני הייתה תקופה של 45 ₪" (פרוטוקול הדיון מיום 22.12.13, עמ' 9 שורות 44-45), הייתה מהימנה עלי ולא הופרכה בחקירתו. עדות זו גם נתמכה במוצג ת/8 (חשבונית בגין תשלום אלדן עבור 100 חניות) ובמכתב השינוי (בו מצוין כי לפי שיטת החישוב הישנה חויבה "אלדן" ב-100 חניות ומצרי ב-20). מנגד, לא הציגה הנציגות ראיה כי חוב זה לא שולם כסדרו, במסגרת תשלומיה השוטפים של שוכרי די ג'יי לנציגות. הוכח בפני כי די ג'יי אף שילמה מעבר לחישוב שהוא לפי שטח דירתה ביחס לשטחי הדירות האחרות (הדברים עולים גם מתחשיבי פרנקל. כך למשל, בעוד שתשלום על פי חלקה היחסי של די ג'יי מגיע בשנת 2009 לסך של 110,982 ₪ מצוין כי היא שילמה בפועל 150,804 ₪. המצב דומה גם ביחס ליתר השנים הרלוונטיות לתביעה). על פי המסגרת הראייתית עליה עמדת לעיל, יש לזקוף סכומים "ביתר" אלו לתשלום עבור אותן חניות.

123. עבור המשרדים של פלאפון ואלדן בחניון 1- הממוקמים ב"מחסנים" – לא מצאתי מקור המצדיק חיוב בגין המחסנים המשמשים כמשרדים בקומת החניון. כאמור, החלטת 2008 התייחסה לחיוב בגין חניות ולא בגין שטחים נוספים. בהיות מחסנים אלו חלק משטחי "הצמדות", והם מצויים בחניון, הרי שלא חלה החובה על פי התקנון המוסכם לחייבם בדמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף (יזכר כי התקנון המוסכם קובע כי יש לחייב מחסנים ב-50% מהתעריף, כל עוד הם אינם ממוקמים בחניון). אף בפועל, לא הוצגו בפני דרישות תשלום מהן ניתן ללמוד כי הנציגות דרשה אי פעם בעבר מדי ג'יי או מי מטעמה לשאת בתשלום עבור אותם מחסנים (בניגוד, למשל, לדרישתה לשלם באופן עצמאי עבור החניות).

124. באשר לחיוב עבור ממ"ד אליו פלשה, על פי הנטען, פון לי בחניון. לטענת הנציגות יש לחייב את די ג'יי עבור שימוש בממ"ד לתקופה של 4 שנים. לא הוכח כי אכן פון לי השתמשה בממ"ד במשך תקופה זו, שכן לא הובאה כל עדות ממנה עולה כי כך היה. די בכך בכדי לדחות טענה זו. ממילא, לא הוכח כי די ג'יי ידעה על השימוש הנטען טרם הגשת התביעה שכנגד. דמי שימוש מגלמים את ערך ההנאה שהופקו מהמקרקעין, ולפיכך היה על הנציגות להוכיח כי **לדי ג'יי צמחה טובת הנאה כלשהי משימוש זה על מנת שתחוב בגינו**. מהסכם השכירות שהציגה די ג'יי (ראה הסכמי השכירות עם פון לי שהוגשו ביום 4.6.13) עולה כי לפון לי



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

הושכרו "מקומות חניה" ולא ממ"ד (ראה הסכם שכירות בלתי מוגנת מיום 13.7.06, שורה 3 - "תיאור המושכר: מקומות חניה..."), כך שלא עולה ממנו כי היא קיבלה תשלום כלשהו עבור השימוש הנטען בממ"ד. מטעמים אלו לא מצאתי בסיס לחיובה של די גיי בגין רכיב זה.

125. אשר על כן לא מצאתי כי קיים כל חוב של די גיי עבור יסודות החוב המפורטים לעיל.
126. טענה שהעלתה הנציגות בתביעה שכנגד היא כי נזקף לחובת די גיי חוב עבור שנת 2012 (סעיף 31 לכתב התביעה שכנגד) בהיקף הבא: "חוב של די גיי (עבור אלדן) בסך 119,057 ₪, חוב של ביקור רופא בסך 13,056 ₪, חוב של מתוקי הראל בסך 2,756 ₪, חוב של צנעני בסך של 5,489 ₪, חוב של מצרי התקנות בסך 31,431 ₪, חוב של פון לי בסך 1,149 ₪, חוב של אלדן בסך 20,550 ₪. כמו כן נטען לחוב בסך 16,027 ₪ עבור דמי ניהול אשר לא שולמו על ידי "בבוש", שוכרת נוספת של די גיי.
127. ביחס לחובות עבור "מתוקי הראל" ו"צנעני", הרי שהנציגות לא חזרה על טענותיה אלו במסגרת תחשיבה בשלב שמיעת הראיות. בתצהיר חבר הנציגות מטעמה, פרנקל, לא הופיעו חובות אלו, כך שיש להניח שאלו נפרעו ומכל מקום התובעת שכנגד לא הוכיחה את קיומם של חובות אלו כלל.
128. בנוגע לחוב עבור ביקור רופא, הרי שבתחשיבי פרנקל החוב עבור "ביקור רופא" נוגע אך לאותו "שטח שירותים שסופח לחב' ביקור רופא". כאמור לעיל, לא מצאתי בסיס לחיוב כאמור.
129. באשר לחובות כביכול של די גיי (עבור אלדן), מצרי ופון לי, הרי שעל פי נספח 1 לתצהיר פרנקל, מדובר בחוב המבוסס על דרישה לתשלום עבור החניות הממוקמות בחניון. כאמור לעיל, לא הוכח בפני די גיי, באמצעות שוכריה, לא נשאה בתשלום עבור החניות, בהתאם להחלטת 2008, ובהתאם לדרישות התשלום שהופנו אליה בזמן אמת, במועדן.
130. בהתייחס ל"חוב אלדן בסך 20,550 ₪", הרי שלא הובהר בכתב התביעה שכנגד, בגין איזה רכיב מבוקש תשלום זה. בנספחי כתב התביעה לא מפורט הבסיס לתחשיב עבור שנת 2012. מנספח 1 לתחשיבים אשר צורפו לתצהיר פרנקל עולה כי חובה של די גיי לשנת 2012 מורכב, בין היתר, מ"חוב אלדן- בגין חשמל ושונות", והוא הועמד שם על סך של 15,183 ₪. ככל שלכך כיוונה התובעת שכנגד בכתב תביעתה, הרי שאדון בכך בפרק הנוגע לחובה הנטען של די גיי עבור שימוש בחשמל.
131. נותר החוב המבוקש עבור "בבוש" על סך של 16,027 ₪, בגין אי תשלום דמי ניהול. בהקשר לחוב זה הרי שאין מדובר בדמי ניהול אשר נגבים בשטחי "הצמדות", אלא בחלק מיחידת משנה 8, בגינה יש לחשב את דמי הניהול על פי הוראות התקנון. די גיי למעשה הודתה, באמצעות מר אסף אבירם מטעמה, בקיומו של חוב זה. בסעיפים 18-19 לתצהיר אבירם נאמר בהקשר זה כך- **"ביחס לטענת הנציגות בנוגע לחוב של "בית קפה בבוש" ... אותו שוכר ("בבוש"), שהחל את שכירותו באוקטובר 2009 החל לצבור חובות בדמי הניהול מיד לאחר שהחל לשכור את המקום. למרות האמור, אף אחד מחברת הניהול לא טרח לעדכן אותי באיחור בתשלומים מצדו במשך כשנתיים, ולכן החוב תפח ותפח..."**
132. בשים לב להודאת די גיי בחוב, הרי שעליה לשאת בו. ככל שבהתאם למערכת החוזית בין די גיי לשוכריה, במקרה זה "בבוש", חלה החובה לשלם את דמי השכירות על השוכר- הרי שעומדת לרשותה האפשרות לפעול



משרד המשפטים לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין ירושלים

באמצעים המשפטיים המתאימים. אולם, על פי הוראות חוק המקרקעין (סעיף 58) החובה לשאת בתשלומי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף חלה על בעל הנכס או החוכר לדורות. במצב דברים זה, לא יכולה די גיי להישמע בטענה כי מדובר בחוב שיש להטיל על שוכריה. היא גם איננה יכולה להיושע מהטענה כי הנציגות לא ידעה אותה בחוב זה במועד. על פי חוק, האחריות לביצוע התשלומים במועד מוטלים על בעל הנכס/ החוכר לדורות ועליו לוודא כי הם אכן מתבצעים כסדרם. **לפיכך על די גיי לשאת בחוב עבור יחידת משנה 8 (החלק שהושכר ל"בבוש") בסך 16,027 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת כתב התביעה ועד לתשלום בפועל.**

שימוש בתשתיות החשמל והמים המשותפים

133. כאמור, טענה הנציגות בתביעתה כי לדי גיי חוב בגין צריכת מים וחשמל, נוכח השימוש בתשתיות הבית המשותף. על פי הטענה, אלדן משתמשת בברזי כיבוי אש הנמצאים בחניון לצורך ניקוי המכוניות. בכתב התביעה שכנגד לא פורט במדויק הסכום המבוקש בגין צריכת החשמל (אלא על דרך הפניה לנספח 3 הכולל בין חובות החשמל חובות נוספים). מנספחי תצהירו של פרנקל עולה כי בגין החשמל נטען לחוב בסך של 15,183 ₪. בגין צריכת המים התבקש בכתב התביעה סכום של 10,800 ₪.

134. די גיי טענה, בין היתר, כי הטענות בגין שימוש בחשמל ובמים הובאו לידיעתה לראשונה במסגרת כתב ההגנה והתביעה שכנגד. הנציגות לא הוכיחה כי די גיי ידעה על החוב הנטען טרם הגשת התביעה שכנגד, וכי הופנו אליה דרישות או בקשות כלשהן בנוגע לכך. ההפך הוא הנכון, אף ממסמכי כתב ההגנה עולה כי הדרישות לתשלום נשלחו רק לאחר הגשת כתב התביעה (ביום 14.8.12 - ראה נספח ב' לכתב ההגנה). במצב דברים זה, לא מצאתי מה המקור מכוחו ניתן לחייב את די גיי בעלויות המבוקשות. ככל שאלדן אכן השתמשה בתשתיות המים או החשמל המשותפות, הרי שעשויה לקום לנציגות עילת תביעה עצמאית כנגדה. אולם, משלא הוכח כי די גיי ידעה על שימוש זה וכי צמחה לה מכך **טובת הנאה**, הרי שלא מצאתי בסיס לחיובה בגין שימוש ברכיבים אלו, כל שאכן נעשה שימוש כזה.

חניית רכבים ב"שטחי המעבר" ודרישה לדמי שימוש ראויים

135. בכתב התביעה שכנגד מבוקש בהקשר זה **"להורות לדי גיי שלא לחנות ב"שטחי המעבר" ולא לחסום אותם**". על פי תשריט הבית המשותף עולה כי "שטחי המעבר" הם אלו: בחניון 1 ו-2 מדובר במשטחים המוצמדים לחלקת משנה 31 (ואינם בחכירת די גיי), וכפופים לזיקת הנאה שמהותה, בין היתר, זכות למעבר חופשי ברכב וברגל (משטחים קצח' ו- קצז'). המשטח, שהוא כאמור בחכירת די גיי, כפוף לזיקת הנאה שמהותה העיקרית זכות למעבר חופשי ברכב וברגל ליתר בעלי הדירות, זאת בהתאם לסימונים המופיעים בתשריט בשטח המקווקו באדום (ראה הערות בדבר זיקות להן כפופה חלקה 31, כעולה מנסח המקרקעין). למעשה, עולה כי "שטחי המעבר" הם משטחים **בבעלות פרטית** הכפופים בחלקם לזיקת הנאה, **ולא רכוש משותף**. מכל מקום, לא הוכח כי שטחי מעבר קיימים גם ברכוש המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

136. שטחי זיקת ההנאה נועדו, כאמור בצו רישום הבית המשותף, למעבר חופשי לרכב והולכי רגל ולפיכך ברי כי אין לחנות בהם, דבר המפריע למעבר חופשי דרכם. אף די גיי לא חלקה כי על כך שאין לחנות בשטחי המעבר, ולמעשה המחלוקות בין הצדדים נסבה על שאלות עקיפות בהקשרים אלו.
137. **לפיכך, אני מורה לדי גיי, או מי מטעמה, שלא לחנות בשטחים הכפופים לזיקת הנאה בכל קומות החניון (המקוויים באדום) ולא לחסום אותם.**
138. באשר לדרישה לחיוב די גיי בדמי שימוש בגין חניה ב"שטחי המעבר" - חסימת המעברים בחניון, כפי שנמצאה בהליך זה, היא באותם "שטחי מעבר" שהם, כאמור, מקרקעין בבעלות פרטית של די גיי הכפופה לזיקת הנאה (להבדיל מרכוש משותף). בדרישתה לחייב את די גיי בדמי שימוש עבור חניות בשטחי המעבר הכפופים ל"זיקת ההנאה", באה הנציגות, לכאורה, בנעלי מוטבי זיקת ההנאה.
139. זיקת הנאה היא **זכות מוגבלת מיסודה (ראה: סעיפים 5 ו- 93 לחוק, ע"א 9308/06 עיריית רמת גן נ' עזבון המנוחה הגב' ורדה ברנשטיין ז"ל [פורסם בנבו] כב' הש' עמית מיום 22.9.11 בס' 58), הפ (י-ם) 613/99 סלמאן נ' עבד אלרחמן [פורסם בנבו], תא 2154/84 הפטריארך הארמני נ' אפרהמיאן, [פורסם בנבו] פ"מ תשמ"ו (2) 492, 509.**
140. **בהיותה זכות מוגבלת, היא אינה מצמיחה לנציגות (גם אם ניתן לראות בה כמי שבאה בנעלי מוטבי זיקת ההנאה) זכאות לדמי שימוש. אין מדובר במקרה בו הנציגות היא בעלת הקרקע ודי גיי הסיגה גבול לשטחה והחנתה בו רכבים. במקרה כזה ייתכן שהיה מקום לחייב את די גיי בדמי שימוש. במקרה הנדון מדובר בטענה בדבר חניה במקרקעיה הפרטיים של די גיי, הכפופים לזיקת הנאה. כמוטבת זיקת ההנאה בשטחי המעבר, לא קמה לנציגות זכאות לדמי שימוש בגין חניות בהם.**
141. **לפיכך התביעה לפסיקת דמי שימוש ראויים בגין חניה בשטחי המעבר - נדחית.**
142. לא אוכל שלא להעיר כי התרשמתי שנושא החנייה במעברים ובשטחי זיקת ההנאה נוגע בנימי נפשה של הנציגות, ומטבע הדברים חניה במקומות אלו עשויה לגרום לטרדה וקושי של ממש בחיי היום יום בחניון. **במצב דברים זה טוב יעשו הצדדים אם יפעלו יחד על מנת לסמן בצורה ברורה את שטחי זיקת ההנאה, וזאת בכדי שלא יטעו גורמים כאלו או אחרים לחשוב כי מדובר במקומות המיועדים לחניית רכבים.**

שימוש חורג

143. הנציגות עתרה לסעד הצהרתי לפיו השימוש שעושה די גיי בחניון, על ידי הפיכתו לחניון תפעולי, הוא בלתי סביר וכמוהו כהסגת גבול. כן התבקשו צווי עשה- להורות לדי גיי שלא להשתמש במחסנים כמשרדים, ושלא להשתמש במשטחים כחניות.
144. למעשה, שלושת סעדים אלו מבוססים על טענות לפיהן מבצעת די גיי "שימוש חורג" במחסנים ובמשטחים, שלא כדין. כך גם הסעד שהתבקש כבר במבוא לכתב התביעה שכנגד (ס"ק ד) הוא- **"... לקבוע כי השימוש שעושים הנתבעים שכנגד בחניון הינו שימוש חורג".**



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

145. כאמור, טענה נוספת שהועלתה היא כי על פי סעיף 9.1 לתקנון הבית המשותף מחויבת די גיי לעשות ביחידתה "שימוש סביר", והשימוש שהיא מבצעת בפועל חורג משימוש שכזה.
146. מקובלת עלי טענת די גיי כי ערכאה זו איננה מוסמכת לדון בסעדים הנוגעים ל- "שימוש חורג" בנכסים פרטיים. המונח "שימוש חורג" מקורו בדיני התכנון והבניה. סעיף 1 לחוק התכנון והבניה התשכ"א- 1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה") מגדיר "שימוש חורג" כך- "שימוש חורג", בקרקע או בבניין – השימוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח מיוחד, לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבניין או לפי היתר על-פי כל חוק הדן בתכנון ובניה". כמו כן קבועות בחוק התכנון והבניה הוראות מגוונות העוסקות בשימוש חורג, הדרך לבקשו והסמכות לתתו (ראה למשל סעיפים 148 ו-149 לחוק התכנון והבניה).
147. המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בסעדים מתחום דיני התכנון והבניה וסמכותו מתמצית בהיבטים הקנייניים בלבד. לא אחת נפסק, כי אין להשוות בין ההסכמות והשיקולים הנוגעים לדיני התכנון והבניה לשיקולים והדרישות הנובעים מחוק המקרקעין (להבדל בין שיקולי הקניין לשיקולי ועדות התכנון ראה למשל בג"צ 1578/90, הלן איזון נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב, ניתן ביום 24.10.90, פורסם ב"נבו"). לפיכך, אינני מוסמכת לדון בסעד המבוקש בכל הנוגע לקביעה כי השימוש שנעשה בחניון הוא "שימוש חורג".
148. המפקח אף אינו מוסמך לדון בסעד זה כעניין שבגררא, שכן במקרה הנדון אין מדובר ב"הכרעה אינצידינטלית" אלא בסעד המבוקש עצמו. סמכות שבגררא לעולם אינה יכולה להקנות זכות לקבלת סעד, רק הסמכות העניינית מקנה זכות כאמור (ראה סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמד- 1984, המאפשר לדון "דרך אגב" בנושא שאינו בסמכות בית המשפט).

שימוש סביר

149. על אף האמור לעיל, מוסמך המפקח על רישום מקרקעין, בין היתר, לדון ב- "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון..." (ראה סעיף 72 (א) לחוק). היות שסעיף 9.1 לתקנון המוסכם קובע, כאמור, כי "על כל בעלי יחידות המשנה להשתמש ביחידותיהם שימוש יעיל וסביר...", הרי שהטענה כי די גיי עושה שימוש המנוגד לסעיף תקנוני זה, הוא בגדר סכסוך בדבר זכויות או חובות בהתאם לתקנון, ולפיכך בסמכותי לדון בו.
150. אשר על כן יש לבחון האם השימוש שעשה די גיי בחניון תואם את חובתה על פי התקנון לעשות "שימוש יעיל וסביר" בהצמדה של יחידת המשנה אותה היא חוכרת לדורות. האם אכן, כנטען, אסור לדי גיי לעשות במשטח שימוש לצרכי חניות, ובפרט חניות כחניות תפעוליות, ולעשות במחסנים שימוש כבמשרדים?
151. הצדדים התייחסו בסיכומיהם לפרשנות המונח "שימוש סביר" בפסיקה. אלא, שהפסיקה שאוזכרה דנה במונח זה בכל הנוגע לרכוש משותף וככזו היא אינה בהכרח מתאימה לפרשנות המונח כשמדובר ביחידה פרטית, כבמקרה הנדון. כך למשל נקבע בפסק הדין המנחה בעניין וינטרס (ע"א 549/73, וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', כח (1) 645) כי שימוש סביר ברכוש משותף, אשר אינו מצריך את הסכמת בעלי הדירות, הוא



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

שימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, התואם את ייעודו של הרכוש המשותף ואשר איננו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה גם המ' 163/81, **בודנוף נ' נציגות הבית ברח' שחראי 14-18**, פ"ד לה (4) 277). כאשר מדובר ביחידה פרטית אין רלוונטיות לתנאים המתייחסים למתן אפשרות לשימוש דומה לאחר. עם זאת, ניתן ללמוד מפרשנות זו כי גם "שימוש סביר" הקבוע בתקנון ביחס ליחידת משנה, צריך שיהיה תואם את תנאי המקום והזמן ואף את יעודה של יחידת המשנה ככזו.

152. ומכאן לנסיבות המקרה שלפנינו. אם נחזור לנושא פרשנות התקנון מההיבט של המונח "שימוש יעיל וסביר" בסעיף 9.1 לתקנון, הרי שמלשון התקנון ניתן ללמוד כי מלוא כובד המשקל ניתן לאי חסימת שטחי המעברים. לא לשווא בסיפא לו הודגש כך- **"בפרט, חל איסור מוחלט על סתימת וחסימת דרכי המעבר ברכוש המשותף, ובמשטחים המפורטים בסעיף 6 לעיל ועל הרמת חפצים המונעים ו/או המפריעים לשימוש בהם"**. מלשון התקנון ברור כי חסימת דרכי מעבר אינו מהווה שימוש סביר לצורך העניין.

153. התקנון שותק בכל הנוגע לשימושים הספציפיים המותרים בחניון, במשטח ובמחסנים שבחניון, הוא אינו מונה רשימה של שימושים כאלו ונראה כי כל עוד משמשים המשטחים כחניות, הרי שמדובר בשימוש התואם את יעוד החניון, וזאת כאמור כל עוד לא מתבצעות חסימות והפרעות לתנועה.

154. מסקנה זו נתמכת בכך שהנציגות עצמה שכרה בעבר את החניות הממוקמות בחניון 1-ו-2 מדי ג'י בעבר (ראה ת/3), דבר המלמד כי אף היא ראתה את השימוש במשטח לצרכי חניות כתואם את ייעודו, וכחלק מהשימושים הסבירים בו.

155. בפועל, נעשה במשטח שימוש לצרכי חניה, אלא שמדובר בחניה של רכבי חברת אלדן, חברה מסחרית שעיסוקה בהשכרת רכבים. האם יש בנתון זה בכדי להוביל למסקנה כי אין המדובר בשימוש יעיל וסביר? הנציגות טענה בהקשר זה כאמור, לרעשים מוגברים, חסימות מעברים, לצפיפות, לכלוך רב, זיהום אוויר, שימוש במוסך ואזור שטיפת מכוניות המעמיס ומקשה על התזוזה בחניון, בלאי מואץ של מתקני החניון לרבות שימוש מרובה במעליות, הזדקקות לשירותי אחזקה ותפעול מוגברים וכד'.

156. בביקוריי במקום, הן זה שנערך בנוכחות הצדדים והן זה האחרון שנערך ללא נוכחותם, התברר כדלהלן: בחניון 1- קיים מבנה המשמש למשרד. כאשר המשטח כולו מחולק לחניון, אזור קבלת רכב ואזור החזרת רכב. קיים גם אזור עליו מוצבים שלטים הנושאים את הכיתוב "מוסכים". בביקורי מיום 28.8.14 הבחנתי בשלטים רבים עליהם נכתב כי "אסור לחנות במעברים". לא הבחנתי ב"מוסך" כלשהו, ובעת הביקור היה מדובר באזור המשמש לחניה בלבד. בכניסה לקומה 1-, קיימות חניות המופרדות בקיר מן האחרות. מדובר באותו חלק אשר שימש בעבר את מצרי ו"פון ליי", ובזמן ביקוריי היה כמעט ריק. בביקורי מיום 28.8.14 חנו במקום כ-2-3 רכבים בלבד, שאינם של אלדן. כאשר לחניות בחניון 2-, הרי שמביקורי עלה כי אלדן עושה שימוש באזור המונה כ-20 חניות, כאשר כרבע ממנו משמש ל"איזור שטיפה". בביקוריי לא הבחנתי בחסימות של דרכי המעבר או בצפיפות הנגרמת מעומס רכבים בחניון.

157. בהקשר לצפיפות ולחסימת מעברים- מהראיות שנשמעו בהליך שוכנעתי כי ככלל, קיימות בעיות של חסימת מעברים וישנה תופעה בה בעלי דירות או שוכריהם מכניסים לחניון רכבים מעבר למספרי החניות המוקצות



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

להם. בעיה זו קיימת ביחס לכלל הדירות ולאו דווקא ביחס לנכסי די ג'י המושכרים לאלדן. כך למשל, עולה ממכתב הנציגות לבעלי הדירות מיום 8.1.12 (נספח י' לתצהיר שושני) - **"לצערנו חלק מהדיירים נוהגים לחנות במקומות לא להם ולחסום מעברם, דיירים מחנים מספר כפל של מכוניות ממספר החניות שברשותם"**. העד חי כהן, מטעם הנציגות, אישר למעשה בעדותו כי כל בעל חניה יכול להכניס כמות רכבים בלתי מוגבלת באמצעות הטלפון הנייד שלו. עוד הוא העיד כי **"דיירים מסוימים מחנים מספר כפול של רכבים"** וכן כי **"אין לנו מעקב אחר כניסת כלי הרכב, לא ידוע לנו בכל זמן נתון כמה רכבים נמצאים בחניון"** (ראה: פרוטוקול מיום 22.12.13, עמ' 6 שורות 10-9, 29-30).

158. באשר לטענות בדבר ניהול "מוסד" ומכון ל"שטיפת רכבים" - לא הוכח בפני כי אכן נעשה שימוש במשטח כבמוסד להבדיל מ"בדיקת רכבים" מינורית. חי כהן אישר בחקירתו הנגדית כי לא קיים "ליפט", הוא איננו יודע אם מחליפים שמני מנוע וראה כי מחליפים פנצ'ר "פעם אחת" (ראה בעמ' 18 שורות 46-28, עמ' 19 שורות 7-1. ראה גם דבריו בעמ' 24 שורות 29-28). כך גם לא הוכח כי כי קיים במקום מתקן לשטיפת רכבים. כאמור, בשני ביקוריי במקום עלה כי הרכבים "מנוגבים" באמצעות מטליות ללא שימוש בצינור מים זורמים. גם לא נשמעו עדויות התומכות בכך שנעשה שימוש כדבר שבשגרה בצינור מים לשם שטיפה, אלא לכל היותר, פעמים ספורות (ראה למשל עדות חי כהן, עמ' 22 שורה 43). לפיכך, לא שוכנעתי כי קיימים "מוסכים" ו"איזורי שטיפה" המעמיסים ומקשים על התזוזה בחניון.

159. בעיות זיהום האוויר בחניון, אף אם קיימות, אינן מלמדות בהכרח על שימוש בלתי סביר בחניון הנוגד את הוראות התקנון המוסכם. ככל שהן קיימות הרי שהנציגות רשאית לפעול בנדון על מנת לצמצמן כאשר בעלויות הכרכות בכך ניתן, ככלל, להכיר ככאלו הכלולות ב"ניהול ואחזקת הרכוש המשותף". במצב דברים שכזה יהא על די ג'י, כאמור, לשאת בחלקה בהתאם להחלטת 2008.

160. באשר לבלאי מואץ והוצאות אחזקה גבוהות, ובכלל זה עליית תכיפות השימוש במעליות, הרי שלא הוכח בפני כי הבלאי הקיים בבניין ומידת השימוש במעליות, קשורים בהכרח לשימוש שעושה אלדן במשטח. יש לזכור כי מדובר בבניין בן 16 שנה לפחות ושחיקת מערכות ומתקנים הקיימים בו הוא דבר טבעי בנסיבות אלו, קל וחומר כאשר מדובר בבית משותף המשמש מספר רב של משרדים ושירותים מסחריים אחרים (בהקשר זה ראה גם נספח י' לתצהיר שושני, מכתב "עדכון פעילות הועד" מיום 8.1.12 ובו הנציגות מציינת כי: **"חלק מבעיות הניקיון קשורים לחומרי הבניין המקורי ולהתיישנותם"** (כך במקור - י.ע.ש), וכן את הדו"חות הכספיים של הנציגות אשר צורפו כנספחים י"ב 1- י"ב 4 לתצהיר שושני, מהם עולה כי הוצאות האחזקה דווקא פחתו בין השנים 2007-2011). מסקנתי היא כי השימוש שעושה אלדן במשטח תואם את ייעודו של החניון.

161. באשר ל- "תנאי המקום והזמן"- מדובר בבית משותף הממוקם בלב אזור תעשייה הומה, ואשר נועד ומשמש עשרות יחידות משנה לשימושים מסחריים. לפיכך, גם בהיבט זה הנטייה היא לראות את השימושים שעושה אלדן בפועל במשטח ובמחסנים, כחניות לרכביה וכמשרדים, כשימושים סבירים.

162. בכל הנוגע לשימוש במחסנים כמשרדים, מעבר לטענות בדבר "שימוש חורג", שכאמור הן אינן בסמכותי, לא מצאתי כל בסיס ראיתי לטענה כי אין מדובר ב"שימוש סביר" כמובנו של מונח זה בתקנון. על פני הדברים



משרד המשפטים
לשכת המפקח/ת על רישום מקרקעין
ירושלים

השימוש במחסנים כמשרדים המשרתים את החניון תואם את יעודו כחניון, ואף תואם את תנאי המקום והזמן. גם הנציגות לא הסבירה בטיעוניה מדוע שימוש במחסנים כמשרדים איננו "סביר" (להבדיל מטענה תכנונית במהותה של "שימוש חורג").

163. אשר על כן מצאתי כי השימוש שעושה די ג'יי בחניון 1- ובחניוניה בחניון 2- איננו חורג מגדר "שימוש סביר" כמשמעו בסעיף 9.1. לתקנון, וזאת, כמובן, כל עוד היא איננה חונה במעברים ובשטחי זיקת ההנאה ואיננה חוסמת אותם בכל דרך שהיא.

164. **יש להדגיש:** קביעותיי לעיל נוגעת לדלת אמות פרשנות המונח "שימוש סביר" בתקנון המוסכם. אין במסקנתי זו בכדי לקבוע דבר וחצי דבר בנוגע לטענות הנציגות בדבר "שימוש חורג". אין בה גם בכדי לקבוע מסמרות ביחס לטענות הנציגות המבוססות על דינים אחרים שאינם בסמכותי, כגון טענות למטרדים המבוססים על דיני הנזיקין, עשיית עושר ולא במשפט וכיוצב'. טענות אלו דינן להתברר בערכאות המוסמכות לכך.

ה. סוף דבר

165. התביעה (210/12) מתקבלת חלקית. הנציגות איננה רשאית להעלות את תעריפי דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף באופן בו עשתה במכתב השינוי ללא שינוי התקנון בדרך הקבועה לכך בחוק. עם זאת, הנציגות רשאית להמשיך לגבות את הוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף בהתאם להחלטת 2008. התביעה הכספית- נדחית.

166. בתביעה שכנגד (281/12) אני מקבלת את הסעד למתן צו עשה ומורה לדי ג'יי או מי מטעמה שלא לחנות בשטחים הכפופים לזיקת הנאה בכל קומות החניון (המקווקווים בתשריט הבית המשותף באדום) ולא לחסום אותם. כמו כן התביעה הכספית מתקבלת בחלקה- די ג'יי תשלם את חובה בגין דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף בסך 16,027 ₪. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד לביצוע התשלום בפועל.

167. שאר הסעדים המבוקשים- נדחים.

168. בנסיבות אלו, יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, כו' אלול תשע"ד, 21 ספטמבר 2014, בהיעדר הצדדים.
המזכירות תשלח לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום מקרקעין